

生醫研究參與者對個別研究結果之近用^{*} —— 法律適用與政策形塑

陳仲嶠^{**}

摘要

在生醫研究進行中，研究者可能生產、獲知某些對個別研究參與者具有健康上價值之資訊。倘若參與者希望知悉與其有關之研究結果，是否得向研究者請求取得？研究者又該採取何種政策，針對不同情形，決定是否主動地向參與者揭露？此一議題已在國際間引起許多辯論。本文之目的，即在探討參與者對研究資料是否存在近用之權利，以及研究者應如何形塑審慎設計而負責任的提供近用政策。

本文認為，在我國法制下，參與者已被賦予取得與其個人連結之個別研究結果的權利；研究者應納入此一法制前提，以及其他事實與倫理面向的考量因素，針對不同情境形塑相應的提供近用政策，並建立適當之個案判斷機制。倘若研究的規劃與執行者願在積極揭露的面向勇敢嘗試，在告知後同意、確認與個案決定、通知等環節上，均應審慎設計，並作出彼此配合的規劃。

* 投稿日：2018年12月21日，接受刊登日：2019年10月2日。〔責任校對：陳怡瑾〕。

作者感謝本刊審查先進的寶貴意見，以及研究助理洪子洵、劉冠佳、陳清暉在資料蒐集與格式校正上的協助。本文之初步想法曾於2016年國立交通大學科技法律學院主辦之「第一屆法與社會研討會」中報告，陳誌雄教授、張兆恬教授等與會先進提供評論與建議，併此致謝。

** 國立清華大學科技法律研究所教授兼所長。

穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/03021002.pdf>。



關鍵詞：結果提供、研究發現、偶然發現、生物資料庫、個人資料
接近權、分析有效性、臨床價值、治療誤解、動態同意。

目 次

壹、前言	三、請求個別研究結果上的解釋適用問題
貳、個別研究結果提供近用的背景與現況	四、法制現況之反思
一、個別研究結果對參與者的價值	肆、政策的願景：提供研究者的思考與建議
二、倫理辯論與政策指引的發展	一、應納入的政策考量
三、國內告知後同意書對提供近用的處理現況	二、橫向架構的確立：消極揭露與積極揭露的區分
參、法律的拘束：參與者的接近權	三、縱向架構的形塑：研究流程的視角
一、比較法的觀察	伍、結論
二、我國法規範概覽	

壹、前言

在生醫研究進行過程中，研究者有可能生產、獲知某些資訊，係對個別研究參與者具有健康上意義者。舉例來說，在蒐集參與者之生物檢體進行基因檢驗後，可能發現該參與者帶有對特定疾病易感性之基因。而參與者是否獲得此一資訊，可能影響其採取預防或治療措施的決定。倘若參與者在提供生物檢體後，希望知悉與其有關之研究結果，是否得向研究者請求獲得該等資訊？研究者又該採取何種政策，能夠衡平各種倫理考量，針對不同情形決定是否被動地甚至主動地向參與者揭露？此一議題已在國際間引起許多辯論，本文之目的，即在探討參與者對研究資料是否存在近用之權利，以及研究者應如何形塑審慎設計而負責任的提供近用政策。

本文認為，在我國法制下，參與者已被賦予取得與其個人連結之個別研究結果的權利；研究者應納入此一法制前提，以及其他事實與倫理面向的考量因素，針對不同情境形塑相應的提供近用政策，並建立適當之個案判斷機制。既有的相關文獻，多集中在倫理層次的辯論與建議，對於既有法制已設下之拘束，往往未加注意。而在法律拘束的分析上，認為不存在任何相關規範的直覺性認知，並非正確之觀察。因為個人資料保護法制——在我國法制下即個人資料保護法（以下簡稱個資法）之規範——所賦予之個人資料接近權，事實上已經是拘束著研究者與參與者資訊流動關係的一項法律規範。在法律義務之外，探究研究者應塑造如何面貌之提供近用政策時，則除了個人對其個人資料的接近權構成不可或缺之考量外，許多其他因素，包括隱私/機密性保護、參與者的偏好、分析有效性（analytic validity; analytical validity; analytical utility）、臨床價值（clinical value）、治療誤解（therapeutic misconception）風險、參與者對資料的理解與使用能力、對研究者的負擔、對醫療體系的負擔與對研究的公眾信賴等，都應被審慎納入考量。

個資法接近權制度對研究者應如何面對個別研究結果之提供，影響重大，其具體之解釋適用，以及制度本身的良窳，均屬重要課題。伴隨待解之諸多法律議題，包括：個資法第10條之得請求範圍，是否包含研究者自行產製而得之個人資料？人體生物資料庫管理條例第10條與個資法第10條，二者規範內涵之關係為何？告知同意書中就接近研究資料所為之內容，產生何等效果？參與者得藉個資法第10條提出如何之請求？研究者接獲請求時，又應如何回應以符合該條之要求？在生物資料庫的情形，與一般研究有何不同？當研究者未遵循規定提供資料時，法律效果為何？更進一步地，現行未設研究例外之接近權制度，是否有值得檢討之處？本文將逐一分析討論。

在概念上值得稍作釐清的是，本文所謂「個別研究結果」，係

指在研究中關於個別參與者的發現，可能是研究原本期望的發現，也可能是非直接相關於研究目的、研究中附帶產生的發現。前者可稱為關於個別參與者的研究發現（*participant-specific research findings*），例如在糖尿病研究中，於特定病患身上找到原即為研究假設的基因變異；後者可稱為關於個別參與者的偶然發現（*participant-specific incidental findings*），例如在藉由基因定序研究族群關聯之研究中，偶然發現特定參與者帶有乳癌易感性基因¹。研究結果整體性的、非針對個人的資訊，稱為一般研究發現（*general research findings*），即非個別研究結果²。因此，雖然是否將一般研究發現回饋給參與者，也是一項研究倫理與政策上的議題，但並非本文的研究範疇³。另外，本文僅探討個別研究結果向參與者本人的開放近用，並不包含是否與何時提供參與者「親屬」的討論⁴，亦不包括特定發現是否應向行政機關呈報之議題⁵。此外

1 Jane Kaye et al., *Can I Access My Personal Genome? The Current Legal Position in the UK*, 22 MED. L. REV. 64, 69-70 (2014). See also NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE, RETURNING INDIVIDUAL RESEARCH RESULTS TO PARTICIPANTS: GUIDANCE FOR A NEW RESEARCH PARADIGM 44-45 (2018).

2 Kaye et al., *supra* note 1, at 69. See also Bartha Maria Knoppers & Amy Dam, *Return of Results: Towards a Lexicon?*, 39 J.L. MED. & ETHICS 577, 578 (2011); Ma'n H. Zawati & Bartha Maria Knoppers, *International Normative Perspectives on the Return of Individual Research Results and Incidental Findings in Genomic Biobanks*, 14 GENETICS MED. 484, 486 (2012).

3 關於提供參與者整體研究結果之議題的探討，see, e.g., Laura M. Beskow et al., *Offering Aggregate Results to Participants in Genomic Research: Opportunities and Challenges*, 14 GENETICS MED. 490 (2012).

4 向親屬提供資訊之議題牽涉許多不同的考量，值得另文探索。關於此議題，see, e.g., Susan M. Wolf et al., *Returning a Research Participant's Genomic Results to Relatives: Analysis and Recommendations*, 43 J.L. MED. & ETHICS 440 (2015); Rebecca Branum & Susan M. Wolf, *International Policies on Sharing Genomic Research Results with Relatives: Approaches to Balancing Privacy with Access*, 43 J.L. MED. & ETHICS 576 (2015); Anne Marie Tassé, *The Return of Results of Deceased Research Participants*, 39 J.L. MED. & ETHICS 621 (2011); Ben Chan et al., *Genomic Inheritances: Disclosing Individual Research Results from Whole-Exome Sequencing to Deceased Participants' Relatives*, 12(10) AM. J. BIOETHICS 1 (2012); Carmen Radecki Breitkopf et al., *Preferences Regarding Return of Genomic Results*

亦值得說明的是，本文討論的「研究」型態，主要是生物醫學研究⁶，而非及於所有以人為研究對象的研究⁷。以生物醫學研究為焦點，係因此類型研究較容易產生具有重大健康影響的發現，而目前相關的倫理辯論也幾乎聚焦於此類型研究，特別是基因體研究或生物資料庫研究。

貳、個別研究結果提供近用的背景與現況

一、個別研究結果對參與者的價值

參與者可能基於健康的理由，或了解家庭譜系或族群身分的原因，乃至出於單純的好奇心，而想知悉與其有關的研究結果。其中最引人關注的層面，當屬這些個別研究結果，有可能對參與者的健

to Relatives of Research Participants, Including after Participant Death: Empirical Results from a Cancer Biobank, 43 J.L. MED. & ETHICS 464 (2015); Conrad V. Fernandez et al., *Canadian Research Ethics Board Leadership Attitudes to the Return of Genetic Research Results to Individuals and Their Families*, 43 J.L. MED. & ETHICS 514 (2015); Karen J. Maschke, *Returning Genetic Research Results: Considerations for Existing No-Return and Future Biobanks*, 13 MINN. J.L. SCI. & TECH. 559, 565-66 (2012); Sarah Scollon et al., *Pediatric Cancer Genetics Research and an Evolving Preventive Ethics Approach for Return of Results after Death of the Subject*, 43 J.L. MED. & ETHICS 529 (2015).

5 例如在美國許多州，研究者依州法對於虐待兒童、虐待長者、自殺風險等有向行政機關呈報的義務。Susan M. Wolf et al., *Managing Incidental Findings in Human Subjects Research: Analysis and Recommendations*, 36 J.L. MED. & ETHICS 219, 242 (2008).

6 所謂生物醫學研究，可參考人體生物資料庫管理條例第3條當中之界定：「指與基因等生物基本特徵有關之醫學研究。」

7 所謂以人為研究對象之研究，或稱為涉及人之研究（research involving human subjects）或人類研究（human subject research），係指以人為對象，使用介入、互動之方法，或是使用其可識別之資料或生物樣本，所進行之研究。其範圍不僅包含以人為對象之生物醫學研究，亦及於以人為對象之社會行為科學與人文科學研究。參照科技部科部文字第1040003540號函；45 C.F.R. § 46.102；邱文聰、莊惠凱，建置當代人類研究倫理的治理架構：一個反身凝視的契機，人文與社會科學簡訊，12卷1期，頁33（2010年）。

康有重要影響，包括協助其避免威脅生命的疾病，或協助找到在個人化醫療下更適合其代謝的藥物；也就是說，這些資訊有可能幫助參與者更了解其健康狀況而據此作成醫療上的決定⁸。影響所及，參與者會有接近個別研究結果的欲望，也就不難想像。

參與者獲得個別研究結果的欲望，已經被諸多調查研究所證實。舉例來說，一項於美國6個地點16個焦點團體進行，對於大型世代研究生物資料庫之公眾態度研究顯示，大部分焦點團體成員對於發現增加氣喘（可治療的病症）風險之基因變異的研究結果，均表示希望取得（對於無法治療的病症以及重要性不明的發現，則態度不一）⁹；大部分成員也建議參與者被給予是否接受資訊、接受資訊之頻率與模式上的選擇¹⁰。另外，一項針對生物資料庫參與者取得555份回覆的調查顯示，90%的回覆者認為研究結果揭露是重要的，對於具體情境的揭露偏好則視下列因素而有所不同：治療的可獲得性（90% vs. 64%）、疾病風險的高或低（79% vs. 66%）、疾病為嚴重或輕微（83% vs. 68%）；過半的回覆者（57%）即使是在研究結果之意義不確定的情況下，仍偏好獲得資訊；而若疾病是高度具遺傳性的，則有高達87%回覆者偏好知悉¹¹。一項橫跨75個國家的大型調查，蒐羅4,961位一般民眾、533位遺傳健康專業人員、843位非遺傳方面的健康專業人員、607位基因體研究人員的態度意見，顯示絕大部分的人都認為，基因體研究中所獲得的不論是相關發現（*pertinent findings*）或偶然發現（*incidental findings*），只要參與者希望獲悉，均應提供給他們¹²；而其中身為一般民眾的回覆

8 Kaye et al., *supra* note 1, at 73.

9 Juli Murphy et al., *Public Expectations for Return of Results from Large-Cohort Genetic Research*, 8(11) AM. J. BIOETHICS 36, 39-40 (2008).

10 *Id.* at 40-41.

11 Nicole L. Allen et al., *Biobank Participants' Preferences for Disclosure of Genetic Research Results: Perspectives from the OurGenes, OurHealth, OurCommunity Project*, 89 MAYO CLINIC PROCEEDINGS 738, 738, 742 (2014).

12 Anna Middleton et al., *Attitudes of Nearly 7000 Health Professionals, Genomic*

者，採此肯定立場者不論是對於相關發現或偶然發現，比例均超過九成¹³。

除了從調查研究顯示參與者的普遍態度外，更直接地是從具體案例觀察中，彰顯個別研究結果確實可能對參與者具有價值。藉由以下文獻中提及之實際案例，本文希望具象地例示對參與者產生的實質利益。在此同時，這些案例或許也可讓吾人反思，是否在任何情境下都可以或應該將資訊告知參與者。

案例一：56歲的病患A進行了胰臟癌手術，並於手術前經告知後同意程序同意參與「澳洲胰臟癌基因體倡議」(Australian Pancreatic Cancer Genome Initiative, APCI)。該倡議為一研究網絡，目標在載錄胰臟癌患者的基因體異常，程序包括蒐集檢體、定序腫瘤與相應正常DNA的基因體，並測繪基因表現與甲基化狀態。遺傳分析(germline analysis)顯示出在BRCA2基因的第11外顯子(exon)存在有害的突變。此一突變被認為會生成BRCA2遺傳性乳癌基因表現，預期將有生涯49%乳癌風險及18%卵巢癌風險。此一結果已由受認證的實驗室以診斷性質的化驗所確認。在發現此一結果時，A正在進行化療。醫師於獲知此一發現後，與A討論轉換為另一種被認為於帶有此種基因突變時更有效的療法之可能性，A同意醫師的建議，並表示很高興能嘗試可能更適合她的不同療法。同時，A也被轉介到一家庭癌症診所，以獲得進一步的諮詢與檢驗¹⁴。

案例二：32歲的病患B為檢查胰臟癌而進行了切片檢查，同時經告知後同意程序同意參與「澳洲胰臟癌基因體倡議」。體細胞分

Researchers and Publics toward the Return of Incidental Results from Sequencing Research, 24 EUR. J. HUM. GENETICS 21, 23 (2016).

¹³ *Id.* at 25 fig.1.

¹⁴ Amber L. Johns et al., *Returning Individual Research Results for Genome Sequences of Pancreatic Cancer*, 6(42) GENOME MED. 1, 2, 5 (2014).

析(somatic analysis)檢測到野生型的KRAS基因與帶有突變的BRAF基因，並經具認證的實驗室所確認。此一突變型式與結腸癌——而非胰臟癌——相一致。此一結果提供給醫療團隊後，B進行了進一步的檢查，而確證了結腸腺癌¹⁵。

案例三：胰臟癌病患C自願加入「胰腺研究生物檢體資源」研究計畫，該研究係以尋找可連結至胰臟癌之基因為目標。惟在研究過程中，研究者發現胰臟癌部分患者亦帶有CDKN2A基因上的突變，而該突變可能導致形成黑色素瘤的較高風險。在一項2011年之研究中顯示，帶有該CDKN2A基因突變者至80歲預期有58%的胰臟癌風險與39%的黑色素瘤風險。不過，獲悉是否帶有此一突變的臨床有效性，仍未確立，例如，並沒有資料能證實此一突變的帶因者若更頻繁地進行皮膚檢驗，能有效降低黑色素瘤發病率。而C是其樣本被研究者發現帶有CDKN2A基因突變的樣本之一¹⁶。

案例四：D是羅瑟蒙-湯姆森綜合症(Rothmund-Thomson syndrome)的患者，此種疾病係一體染色體隱性遺傳的罕見疾病，以於嬰兒時期開始出現的特殊皮膚疹為表徵，其他相關特徵包括短矮身材、頭髮與指甲異常、早發白內障以及骨骼異常等。一項探索該疾病癌症風險與試圖尋找關聯基因的研究計畫，於1999年在部分疾病家族的分析中發現有RECQL4基因的突變，並開始進行所有參與研究之家族樣本的RECQL4基因定序；後來的研究結果顯示，大約65%的病患有該基因突變，而同時患有骨肉瘤的病患有，則幾乎全部都有該基因突變。D及其父母於1999年時參與了RECQL4基因之分析研究，而在研究中D的樣本被辨識出存在基因突變。D的父母及其醫師於2003年時聯繫研究團隊，表示D的父母正準備迎接第二

¹⁵ *Id.* at 6.

¹⁶ Laura M. Beskow & P. Pearl O'Rourke, *Return of Genetic Research Results to Participants and Families: IRB Perspectives and Roles*, 43 J.L. MED. & ETHICS 502, 503 (2015).

個小孩，希望可以取得相關資料，以作為產前諮詢與檢驗之用。這尤其是因為，當時並不存在任何檢驗單位提供RECQL4基因產前篩檢的服務¹⁷。

暫且不論揭露研究結果所涉及的其他考量，上述實際案例至少呈現了研究資訊對參與者之價值的一些潛在態樣。案例一顯示個別研究結果可能對參與者在治療方法選擇上產生助益。案例二顯示了對參與者疾病診斷上有所幫助。案例三則是，資訊對參與者未來有健康上重要性但臨床有效性存在疑問的例子，雖然此類資訊的提供究竟能否實質增進參與者的健康或反而造成參與者的困擾，有所爭議，但可以肯定的是，至少有些參與者會想要獲悉該等資訊。案例四中則顯示研究發現的價值，除了在本人的健康層面外，亦可能顯現在相關人生育決定上的重要性。

二、倫理辯論與政策指引的發展

對參與者具有價值，並不代表個別研究結果就必然應該提供給參與者。學界對此議題爭論不休，雖然國際間逐漸形成朝向原則贊成的共識，但反對的聲音仍不可輕易忽視。相關討論意見紛呈，但論者觀察正反二方論述，或整理三種立場的類型化作法，具有便於理解之功，以下將循這些方式呈現相關的倫理辯論。

一項整理正反雙方論點的回顧研究指出，支持方的見解主要立基於對人的尊重（respect for persons）之倫理原則，導出個人有獲得研究結果的權利，且與參與者分享結果的作法，也進一步將參與者作為研究夥伴——而不只是達成研究目的的工具——的努力強調出來¹⁸。另外，支持方也認為，參與者的健康利益是一項重要考

¹⁷ Scollon et al., *supra* note 4, at 531.

¹⁸ Murphy et al., *supra* note 9, at 37. See also NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE, *supra* note 1, at 61-62.

慮，尤其在研究結果是科學上有效、健康上重要且臨床上有行動可能時，更應當揭露給參與者¹⁹。相對地，反對方則主張，提供個別研究結果混淆了研究與醫療，將造成參與者落入「治療誤解」，錯誤地期待於未來接收到醫療相關資訊，甚至因為此一誤解而決定加入研究。同時，參與者若取得不確定或無法解讀的資料，更可能陷入焦慮或不斷從事無必要的檢驗。另外，加諸提供資訊的義務，將成為研究者沉重的負擔，有論者甚至認為將拖緩基因研究的進展。尤其是，研究者本身可能不具備適當的專業，去辨識與報告對參與者有健康價值的個別研究發現，研究者可能需要額外納入專業人員來履行此一任務；又為了符合法令所要求的實驗室檢驗標準，個別研究結果還須送交臨床實驗室重新檢驗。這些都是偏離研究本身的額外負擔。此外，再次聯繫參與者以提供個別研究結果，也產生包括「不知的權利」(right not to know) 等的隱私議題。在生物資料庫情形，資料庫與研究者須負擔多久的提供結果義務，也成為疑問²⁰。

19 See Murphy et al., *supra* note 9, at 37. See also NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE, *supra* note 1, at 62-63。此一觀點主要建立在行善(beneficence)與救助義務(duty to rescue)之倫理原則，相關論述，see, e.g., Elizabeth R. Pike et al., *Finding Fault? Exploring Legal Duties to Return Incidental Findings in Genomic Research*, 102 GEO. L.J. 795, 804-05 (2014); Emmanuelle Lévesque et al., *Return of Research Results: General Principles and International Perspectives*, 39 J.L. MED. & ETHICS 583, 584 (2011)。另外，從互惠原則(reciprocity)出發，基於參與者對研究之貢獻應得到回報的觀點，而導出應將個別研究結果告知參與者的見解，see, e.g., Pike et al., *supra*, at 804-06; Wolf et al., *supra* note 5, at 229。

20 Murphy et al., *supra* note 9, at 37. See also NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE, *supra* note 1, at 63。另關於反對意見的論述，see, e.g., Ellen Wright Clayton & Amy L. McGuire, *The Legal Risks of Returning Results of Genomics Research*, 14 GENETICS MED. 473 (2012); Joanna Stjernschantz Forsberg et al., *Changing Perspectives in Biobank Research: From Individual Rights to Concerns about Public Health Regarding the Return of Results*, 17 EUR. J. HUM. GENETICS 1544 (2009); Lisa S. Parker, *Returning Individual Research Results: What Role Should People's Preferences Play?*, 13 MINN. J.L. SCI. & TECH. 449, 481-83 (2012); Leslie Meltzer Henry, *Undesirable Implications of Disclosing Individual*

在上述對提供個別研究結果支持與質疑的各種論述下，產生了至少三種政策立場。一是在任何情境均不提供；「英國生物資料庫」（UK Biobank）即是採此政策之適例。二是只要參與者期望如此，所有的個別研究結果均應提供給參與者；例如「愛沙尼亞基因銀行」（Estonian Gene Bank），允許個人接近其所有紀錄與基因資料（但不包括家系資料），另外如「國際醫學科學組織理事會」（Council for International Organizations of Medical Sciences）針對流行病學研究的倫理指引，也表示個人應被告知其健康狀態。三則是中間立場，也就是肯認特定情形的個別研究結果，個人有權獲得；至於何種特定情形屬之，見解紛呈。一個美國衛生研究院（National Institute of Health, NIH）提出的大型世代研究計畫採取的標準，係視該個別研究結果是否具備科學有效性、臨床重要性，且對參與者有潛在的利益²¹。其他較受關注的二個方案，一是建議納入研究結果之分析有效性與臨床有效性、研究脈絡、對參與者的個人意義、參與者－研究者關係之本質等數項因素，來決定是否揭露個別結果；二是建議由參與者於加入研究時，自己來選擇希望取得的結果的類型²²。整體而言，多數探討此議題的論者採取中間立場，肯定在某些情形存在提供個別研究結果的倫理義務，並試圖界定應提供的特定情形²³。

國際間的倫理指引，似亦逐漸朝向原則肯認提供的方向，但對於判斷是否提供的標準以及提供是否為義務等問題，仍有所分歧。一項2011年整理了國際間10個觸及此議題的倫理指引的研究指出，

Genetic Results to Research Participants, 6(6) AM. J. BIOETHICS 28 (2006).

21 Kristien Hens et al., *The Return of Individual Research Findings in Paediatric Genetic Research*, 37 J. MED. ETHICS 179, 180 (2011). See also Maschke, *supra* note 4, at 561-62.

22 Murphy et al., *supra* note 9, at 37-38; Hens et al., *supra* note 21, at 180.

23 Pike et al., *supra* note 19, at 809-10. See also Anya E.R. Prince et al., *Automatic Placement of Genomic Research Results in Medical Records: Do Researchers Have a Duty? Should Participants Have a Choice?*, 43 J.L. MED. & ETHICS 827, 829 (2015).

雖未呈現共識，但這些倫理指引共同證明了，在部分情形提供個別研究結果被認為是倫理上可接受的；而關於應或得提供的特定情狀為何，在有列出判斷標準的倫理指引當中，多數提到與二個面向有關的標準：（1）結果正確性與（2）健康相關性²⁴。更晚近的例子，例如國際性聯合組織「基因體與社會公共人群計畫」（Public Population Project in Genomics and Society, P³G）於2012年發布的政策聲明，表示「當研究者在與其當地研究倫理委員會合作下，認定下述標準合致時，應考慮提供個別研究結果或偶然發現：1. 參與者於初始之同意書中或其後已同意；2. 該發現為分析上有效的（亦即被獨立地加以確認）；3. 該發現反映了嚴重健康狀況的重要風險；且4. 該發現存在行動可能（actionable）。²⁵」另外，「當研究者在與其當地研究倫理委員會合作下，認定上述標準不滿足，但下述標準合致時，得考慮提供個別研究結果或偶然發現：1. 參與者於初始之同意書中或其後已同意；2. 該發現為分析上有效的（亦即被獨立地加以確認）；3. 該發現反映了對參與者相當可能有健康重要性之已確立的風險；且4. 該發現存在相當可能的治療上益處。²⁶」

另外，一項2011年整理美國10個相關倫理指引或政策建議的研究，亦呈現當中有9個認同至少在某些情形提供個別研究結果²⁷。至於在何種情形提供，該研究認為雖欠缺共同接受的標準，但許多指引或建議都特別重視科學有效性、臨床重要性與治療可獲得性等因素²⁸。其中典型的例子，如國家心、肺與血液研究院（National Heart, Lung, and Blood Institute, NHLBI）2009年工作小組所提出的

24 Lévesque et al., *supra* note 19, at 588.

25 Bartha Maria Knoppers et al., *Population Studies: Return of Research Results and Incidental Findings Policy Statement*, 21 EUR. J. HUM. GENETICS 245, 247 (2013).

26 *Id.*

27 Christopher A. Cassa et al., *Disclosing Pathogenic Genetic Variants to Research Participants: Quantifying an Emerging Ethical Responsibility*, 22 GENOME RES. 421, 422 (2012).

28 *Id.* at 421-22.

建議，明確建立：「如果個別的基因結果符合以下所有標準，應被提供給研究參與者：a. 該基因發現對參與者具有重要的健康影響，且關聯風險已被確立並實質重要。b. 該基因發現存在行動可能，也就是說，存在已確立的治療或預防方法，或其他有潛力改變疾病臨床進程而可獲得的措施。c. 所進行之檢測在分析上具有有效性，且揭露計畫符合所有相關法律。d. 在告知後同意的程序中或後，研究參與者已選擇接受其個別基因結果。²⁹」另外，在前述條件未能完全滿足，但符合以下所有標準時，「研究者得選擇提供個別的基因結果給研究參與者」：「a. 研究者已認定，對於參與者來說揭露的潛在利益大於風險。b. 研究者的研究倫理委員會（IRB）已認可揭露計畫。c. 所進行之檢測在分析上具有有效性，且揭露計畫符合所有相關法律。d. 在告知後同意的程序中或後，研究參與者已選擇接受其個別基因結果。³⁰」更晚近的例子如二個研究網絡「臨床定序探索研究」（Clinical Sequencing Exploratory Research）與「電子醫療紀錄與基因體」（Electronic Medical Records and Genomics）共同組成的研究會議，提出以下建議：「分析上與臨床上有效、具有重要而存在行動可能之醫療本質，且係於研究程序中被識別出來的資訊，應被提供給研究參與者。³¹」而此係以參與者已於告知後同意程序中同意取得該等資訊為前提³²。

最新一項重要的政策建議發展，是美國國家科學院、國家工程學院與國家醫學院（The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine）聯合發布的共識研究報告「提供個別研

29 Richard R. Fabsitz et al., *Ethical and Practical Guidelines for Reporting Genetic Research Results to Study Participants: Updated Guidelines from a National Heart, Lung, and Blood Institute Working Group*, 3 CIRCULATION: CARDIOVASCULAR GENETICS 574, 575 (2010).

30 *Id.* at 577-78.

31 Gail P. Jarvik et al., *Return of Genomic Results to Research Participants: The Floor, the Ceiling, and the Choices in Between*, 94 AM. J. HUM. GENETICS 818, 821 (2014).

32 *Id.*

究結果予參與者：新研究典範之指引」。其結論指出，「除了在可靠的研究結果顯示參與者處於立即危險的情況下之外，研究者決定不提供結果——只要同意程序中已指出結果將不會被提供——並不必然違反人類研究之倫理原則。沒有一項倫理原則充分正當化不受限制的，向參與者提供研究結果的義務，但也沒有任何倫理原則完全豁免研究者於如此行動。³³」同時其亦指出，「將提供個別研究結果之倫理與社會考量的完整面向納入考慮後，很清楚地，存在特定情境具有強烈的理由將個別研究結果提供給參與者，也存在其他情境限制與拘束結果提供是適當的。對於任何特定研究，在決定是否提供結果上，不同的倫理原則必須被平衡，而情境的特定脈絡必須被小心地考慮。³⁴」在此抽象結論下，該報告進一步提出幾項原則：第一，基於研究結果對許多參與者具有價值，在研究計畫之設計中，研究結果之提供應被慣常性地考量；第二，基於研究具有重要的社會價值，提供個別研究結果在參與者、研究者、研究機構與社會上付出的代價，亦應被審慎考量；第三，當個別研究結果被提供時，參與者有權決定是否接受；第四，當個別研究結果被提供時，溝通程序乃重要環節，以促進資訊意涵、潛在使用與限制之理解；第五，研究結果之價值仰賴該結果之有效性與可信賴性，而結果之有效性與可信賴性仰賴實驗室品質的高標準；第六，研究者應以涵容完整面向之社群需求與偏好，不論參與者之社經背景的方式，實踐個別研究結果之提供³⁵。

從上述國際間與在美國的發展來看，認為在特定情形應提供個別研究結果給參與者的看法，已是逐漸浮現的共識。然而，相關的爭論、研究與具體實踐，仍在持續發展中³⁶。不僅質疑的見解不應

33 NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE, *supra* note 1, at 66.

34 *Id.* at 80.

35 *Id.* at 82-85.

36 Susan M. Wolf, *The Past, Present, and Future of the Debate over Return of Research*

輕易忽視，即使採取特定情形肯定的中間立場，應採如何的判斷標準仍存在歧見。而即使接納晚近似乎較具影響力的看法——也就是著重分析有效性、臨床重要性與臨床可行動性等標準，這些標準意涵為何？如何具體適用？仍存在許多不一致與不確定³⁷。

三、國內告知後同意書對提供近用的處理現況

雖然國際間對參與者近用之討論如火如荼，許多生物資料庫或研究計畫也已將提供個別研究結果付諸實行³⁸，但在國內似仍未受關注，也欠缺具體實踐。這從國內研究用的告知後同意書的內容，似未正面處理對參與者之提供近用議題，或僅直接採取否定立場，可以看出。

在生物資料庫的脈絡，首先可以衛生福利部所發布之「人體生物資料庫參與者同意書參考格式」，作為觀察的切入點，蓋國內生物資料庫的設置者應很自然會傾向於採納該官方發布之同意書範本。在該參考格式第九點「自生物檢體所得之基因資料，對參與者及其親屬或族群可能造成之影響」項下，以舉例方式建議同意書可納入下述內容：「研究結果有可能以集體資料加密交叉比對的方式，就特定基因與疾病、生活型態等因素分析其相關關係，如果您

Results and Incidental Findings, 14 GENETICS MED. 355, 356 (2012).

37 Pike et al., *supra* note 19, at 809-11. 另外，一項以99種具體病症或基因來詢問16位專業人員的實證調查研究，也顯示實際判斷應否提供個別結果上的歧異，Robert C. Green et al., *Exploring Concordance and Discordance for Return of Incidental Findings from Clinical Sequencing*, 14 GENETICS MED. 405, 409-10 (2012).

38 調查分析國外生物資料庫或研究計畫實際處理此一議題情形的研究，e.g., Gail E. Henderson et al., *The Challenge of Informed Consent and Return of Results in Translational Genomics: Empirical Analysis and Recommendations*, 42 J.L. MED. & ETHICS 344 (2014); Susan M. Wolf et al., *Managing Incidental Findings and Research Results in Genomic Research Involving Biobanks and Archived Data Sets*, 14 GENETICS MED. 361, 365-66 (2012); Rachel B. Ramoni et al., *Experiences and Attitudes of Genome Investigators Regarding Return of Individual Genetic Test Results*, 15 GENETICS MED. 882, 883-84 (2013).

的親屬或族群帶有經上述分析證明具特定疾病風險的基因或其他因素，可以協助他們採取可行的預防或早期檢測之措施。³⁹」此一告知內容，乍看似與本文討論議題有關。不過仔細推敲其意，似僅在表示研究結果的社會貢獻，也可能使參與者的家族或族群受益。從該文句中無法解讀出，生物資料庫承諾會將研究結果通知參與者或其親屬之意涵。事實上，在該參考格式第十一點「排除之權利」項下，有如下明確有關參與者近用研究結果事項的建議文字：「1. 本庫是以醫學研究為目的，資料、資訊分析之結果，係以群體（非以個人）方式呈現，因此不會通知您任何檢查、檢驗或研究結果。2. 本庫之生物檢體或資料、資訊之蒐集、處理，均以群體方式為之。因此，本庫無法提供任何個人資料、資訊之閱覽、複製、補充或更正。但您的姓名、地址、聯絡方式等變更時，可以通知我們更正。⁴⁰」明白否定通知參與者個別研究結果之可能，甚至在參與者主動要求取得時，生物資料庫也會拒絕。

另以設置於中央研究院之「臺灣人體生物資料庫」為例，其參與同意書中並未直接處理提供個別研究結果之議題，但有部分文句與此議題有關。該同意書中提到，「因本資料庫專以生物醫學研究為目的，並非旨在提供健康檢查，因此除非您向我們要求寄發檢查報告，否則前述對參與者進行的檢測結果，我們將不通知。⁴¹」而該文句中之所謂檢查報告，依同意書相關內容觀之，應指血液檢驗（包括紅血球、飯前血糖、糖化血色素、膽固醇、高密度膽固醇、三酸甘油脂、尿酸、尿素氮、肌肝酸、肝功能檢驗與肝炎病毒指標，如：C型肝炎病毒抗體、B型肝炎的抗原、表面抗體與核心抗

39 衛生福利部醫事司，人體生物資料庫參與者同意書參考格式，<https://www.mohw.gov.tw/dl-20320-74613f8d-ee25-4c1c-8a89-88cae66ff7cb.html>（最後瀏覽日：2018年4月6日）。

40 同前註。

41 臺灣人體生物資料庫，參與同意書，頁10，http://www.twbiobank.org.tw/new_web/download/同意書_健康人版.pdf（最後瀏覽日：2018年4月6日）。

體等檢查)、尿液檢驗(包含微量白蛋白等檢查),以及基本身體檢測(包括身高、體重、體脂肪、腰圍及臀圍測量、血壓、脈搏、肺功能檢測、骨密度檢測等檢測)⁴²。詳言之,「臺灣人體生物資料庫」會對參與者進行特定的血液檢驗、尿液檢驗與基本身體檢測,以取得部分基本健康資料,作為後續提供研究的基礎。該等資料是預期產出,而非偶然發現的結果,但既與個別參與者有關且為研究過程之產物,仍屬本文個別研究結果概念之一環。因此可以說,該同意書並未直接針對個別研究結果的近用議題完整處理,但對其中一部分預期產出的特定資料,有揭示其參與者近用政策。而針對該特定資料之近用政策,簡言之,即在參與者未要求取得的情形,採取否定立場;在參與者要求取得的情形,採取肯定立場⁴³。

另於一般研究計畫的脈絡,可以國立臺灣大學醫學院附設醫院與國立成功大學醫學院附設醫院等的研究參與同意書範本為例來觀察。國立臺灣大學醫學院附設醫院的「研究受訪者說明及同意書」於「受訪者權利」項下,提到「(一)研究過程中,與您的健康或是疾病有關,可能影響您繼續接受本研究的任何重大發現,都將即時提供給您。⁴⁴」此一條款對於提供給參與者,僅限於影響參與者繼續參與該研究之發現,且並非僅針對與參與者個人相關的研究結果,應屬確保參與者退出研究之權利的一環⁴⁵,而非為回應本文議

⁴² 同前註。

⁴³ 另外值得附帶一提的是,基於其檢驗結果的分析有效性不等同於臨床檢驗的考量,該同意書中並敘明:「我們所寄發之檢查報告將僅列出相關檢驗值以供您參考,性質並不同於醫療院所之正式健康檢查報告。由於檢查報告必須與臨床其他資訊做結合,方能做出有意義的醫療診斷,同時本資料庫之人員亦不具備診斷資格,故不提供醫療諮詢。本檢驗結果無法取代醫療院所之檢驗報告,但為有助於提升健康品質,我們鼓勵您持檢查報告至所在地衛生所或其他醫療院所尋求諮詢服務。」同前註。

⁴⁴ 國立臺灣大學醫學院附設醫院,研究受訪者說明及同意書, <https://www.ntuh.gov.tw/RECO/application/DocLib7/07.研究受訪者說明及同意書.doc> (最後瀏覽日:2018年4月6日)。

⁴⁵ 關於研究參與者的退出研究之權利,已被納入於我國實定法中。參照人體研究

題所設。可以想見在該條款下，研究中發現實施於參與者身上的研究儀器，有超出原先告知參與者之放射性暴露風險時，此等一般性發現應立即通知所有參與者，以利其決定是否繼續參與研究；但相對地，研究中發現個別參與者帶有特定疾病的易感性基因，雖對參與者未來於預防或治療上或有潛在助益，但與是否繼續參與研究之決定無關者，似即不在提供的範圍內。國立成功大學醫學院附設醫院的「人體研究說明及同意書」在「受試者權利及個人資料保護機制」項下，亦有「研究過程中如有新資訊可能影響您繼續參與研究意願的任何重大發現，都將即時提供給您」之文句⁴⁶，應作類似之理解。亦即，這些同意書並未針對提供個別研究結果予參與者之議題，有所意識並直接回應，而僅在為落實參與者退出研究之權利的理念下，加諸研究者提供影響參與者繼續參與研究之資訊的義務。

由此可見，國內實務關於提供個別研究結果的議題，並未有所意識。也因此可以預期，當個別研究結果在研究過程中出現，生物資料庫或研究者恐怕不會特別去思考是否應向參與者揭露的問題。甚至當參與者的具體請求臨門時，生物資料庫或研究者也恐怕未準備好如何面對。因此，本文後文之探索，也就更加突顯其價值。

參、法律的拘束：參與者的接近權

如前言中已約略提及的，既有的討論範疇多集中於倫理層次的辯論與建議，對於法律所設下之拘束，往往未加觸及。部分原因或許在於，尚無法律規範直接處理此一議題，例如在我國或美國，均

法第14條第1項第6款、醫療法第79條第3項第5款、人體生物資料庫管理條例第8條。

46 國立成功大學醫學院附設醫院人體試驗委員會，人體研究說明及同意書，http://www.ncku.edu.tw/nckuhirb/upload/download_form/03001S_A049NEW.doc（最後瀏覽日：2018年4月6日）。

是如此⁴⁷。不過，既有討論往往忽略的是，個人資料保護法制中關於個人資料接近的權利，事實上已經為特定情境下的近用定下應遵循的規範。所謂對個人資料的接近權（the right of access to personal data），係指個人對其個人資料知悉、查詢或查閱的權利，並可包含更正錯誤個人資料的權利；此權利之賦予，廣為個人資料保護之國際規範與各國法制所採⁴⁸。本章之目的，即在從個人資料接近權的角度，呈現現行法在提供個別研究結果議題上的解釋適用。值得稍作說明的是，前開界定之國際間隱私保護準則與規範中廣泛存在的right of access概念，在國內如何稱之，尚無定論。少數觸及之學術著作，對於access一詞有譯為接近⁴⁹，有譯為接近使用⁵⁰，亦有譯為近用⁵¹者。本文認為此些譯法均屬妥適，而基於此權利之概念重點

47 美國之情形參照Emily Scholtes, Note, *Incorporating Cost into the Return of Incidental Findings Calculus: Defining a Responsible Default for Genetics and Genomics Researchers*, 100 MINN. L. REV. 1171, 1172, 1180 (2016).

48 See, e.g., ORG. FOR ECON. CO-OPERATION & DEV. [OECD], OECD GUIDELINES ON THE PROTECTION OF PRIVACY AND TRANSBORDER FLOWS OF PERSONAL DATA, at art. 13 (1980), <https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdguidelinesonthe protectionofprivacyandtransborderflowsofpersonaldata.htm>; ASIA-PACIFIC ECON. COOPERATION [APEC], APEC PRIVACY FRAMEWORK, at art. 23 (2005), http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/~media/Files/Groups/ECSG/05_ecsg_privacyframework.ashx; ORG. FOR ECON. CO-OPERATION & DEV. [OECD], THE OECD PRIVACY GUIDELINES, at art. 13 (2013), http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf; *infra* notes 53, 56, 65.

49 邱文聰，從資訊自決與資訊隱私的概念區分——評「電腦處理個人資料保護法修正草案」的結構性問題，月旦法學雜誌，168期，頁175（2009年）；周慧蓮，資訊隱私保護爭議之國際化，月旦法學雜誌，104期，頁119（2004年）；陳秀峰，線上個人隱私之保護，月旦法學雜誌，82期，頁211、213（2002年）。

50 劉靜怡，淺談GDPR的國際衝擊及其可能因應之道，月旦法學雜誌，286期，頁16（2019年）；洪子洵，外國法與我國健保資訊應用之比較——以美國醫療保險可攜性及責任法（HIPAA）為鑑，醫事法學，20卷2期，頁37（2013年）。

51 翁逸泓，OTT發展之隱私與個人資料保護問題初探，世新法學，10卷1期，頁50（2016年）；顏上詠，台灣人體生物資料庫管理條例草案評析，月旦法學雜誌，168期，頁158（2009年）；張腕純，個資保護與公共事務資料應用之權衡——歐盟GDPR公共利益歸檔、科學或歷史研究或統計之例外規定及英國之實踐，科技法律透析，31卷2期，頁20（2019年）。

較集中在「接近取得」之意涵，接近取得後得以「使用」乃自然附隨之效果，故暫以接近權稱之。至於本文中亦出現之近用一詞，則僅為描述性詞彙，並非用以指涉前開或任何明確界定的權利概念，為避免誤解，謹此敘明。

一、比較法的觀察

個人對其個人資料之接近權，固然已是廣泛受到肯認的概念，但其內涵與範圍，未必有普世一致的面貌。尤其是，此一權利就像所有其他權利一樣，須與其他權利的保護相調和。因此在法制上，在何種程度內賦予該項權利，或該項權利之行使帶有何種之例外，涉及立法政策之考量，未必各國均規範相同。在進入我國法制分析之前，值得藉由幾個比較法上的例子，來呈現理論上可能的設計。

歐盟的個人資料保護法制向來是我國借鏡的對象之一，而甫於2016年通過於2018年5月15日生效的資料保護一般規則（General Data Protection Regulation）⁵²，更是須投以關注的晚近發展。該規則第15條確立資料主體的接近權，表明「資料主體有權向資料控制者確認是否其個人資料正被處理，若然，有權接近該個人資料及下列資訊……」⁵³。在此同時，該規則第89條規定，「在個人資料係為科學或歷史研究之目的或統計之目的而處理之情形」，於具備特定條件與保護措施之前提下，「若該等權利相當可能使得前述特定目的無法達成或造成嚴重阻礙，歐盟或會員國之法令得規範減損第15、16、18及21條所賦予之權利」⁵⁴。基此，一般而言，參與者應具有向研究者接近取得其個人資料的權利；但是，由於科學研究正

52 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC, 2016 O.J. (L 119) 1.

53 *Id.* at 43.

54 *Id.* at 84-85.

屬例外條款所描述的情境之一，因此並不排除歐盟或會員國為某些情形下不提供個別研究結果，建立法令上的依據。

英國的1998年資料保護法（Data Protection Act 1998），是一個為研究目的創設有接近權例外條款的例子⁵⁵。該法第7條規定，個人有權要求資料控制者提供其個人資料的描述，以及以可理解形式傳達構成其個人資料的資訊⁵⁶。而在同法第33條，則明確為研究目的規定了排除第7條權利之可能：「如符合下述情形，僅為研究目的而處理之個人資料，被豁免於第7條之外：(a)該資料係於符合相關條件下處理，且(b)研究結果或任何產生之統計，不以可辨識資料主體之方式呈現。⁵⁷」而(a)款中所謂的「相關條件」，依同條之界定，係指「(a)該資料並非為支持有關特定個人之措施或決定而處理，以及(b)該資料並不以會造成資料主體實質傷害或實質痛苦之方式處理。⁵⁸」在生醫研究中產生之個別研究結果，由於僅僅是研究過程中的產物，通常都非用於作成針對參與者之措施或決定，且資料處理方式也不造成參與者實質傷害或痛苦，又最後的研究結果，也幾乎都是整體性地呈現，而不揭露任何參與者身分。因此在此法下，個別研究結果原則上應該會落入例外條款，即使參與者提出請求，研究者亦無提供資料的法定義務。當然，不排除在某些研究情境，參與者所欲請求之資料除研究使用外，同時也用於作成與參與者個人有關的研究上或醫療上之決定⁵⁹。此時，該等資料即不符合

⁵⁵ 英國的資料保護法為因應有直接適用效力之歐盟資料保護一般規則，於2018年大幅修正。針對資料主體之接近權，新法規定，若符合歐盟資料保護一般規則第89條之要件且研究結果不以可識別性之方式呈現，即排除接近權規定之適用，Data Protection Act 2018, c. 12, § 15, Sch. 2。但由於新法係在歐盟資料保護一般規則架構下並與之具原則上之一致性，相比起來舊法較有立法例觀察上之特殊價值，故本文選擇以舊法作為觀察比較之例，合先敘明。

⁵⁶ Data Protection Act 1998, c. 29, § 7.

⁵⁷ Data Protection Act 1998, c. 29, § 33(4).

⁵⁸ Data Protection Act 1998, c. 29, § 33(1).

⁵⁹ 參照後文註68附隨本文所舉臨床試驗之例。

例外要件，而得為參與者請求之標的。

在美國，不同於歐洲與許多其他地域之國家，其個人資料保護法制係分散性地針對個別事務領域而制定⁶⁰；其中與健康資訊有關者，為健康與人類服務部（Department of Health and Human Services）依據「健康保險可攜性與可責性法」（Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA）⁶¹所制定之隱私規則（以下簡稱HIPAA隱私規則）⁶²。HIPAA隱私規則在適用主體上，僅限於健康計畫、健康照護清算中心，以及健康照護提供者（限於以電子形式傳輸與該規則所涵蓋之交易有關之健康資訊的健康照護提供者）等機構⁶³。另外在保護標的上，限於所界定之「受保護健康資訊」（protected health information），而此一概念的涵蓋範圍，基本上係以「個人可辨識性健康資訊」（individually identifiable health information）為基礎，排除幾種特定情形而成，故其內涵之本質，大體上可從「個人可辨識性健康資訊」之定義來了解。「個人可辨識性健康資訊」係指健康資訊之一種，且「(1)由健康照護提供者、健康計畫、公共衛生機關、雇主、壽險業者、學校或大學，或健康照護清算中心所創造或接收到，且(2)有關於個人過去、現在或未來之生理或心理健康或狀態，或有關於對個人提供之健康照護，或有關於為對個人提供健康照護之過去、現在或未來的付款，而(i)可識別個人，或(ii)就其而言，有合理之基礎相信該資訊可用於識別個人。⁶⁴」在上述受限的適用範圍下，顯然並非所有研究或其資訊使用情境，均會受到該規則的管制。不過，該規則所建立的個人資料接近權及其例外規定，仍可作為比較法上參酌之一例。

60 See ANITA L. ALLEN, *PRIVACY LAW AND SOCIETY* 645-49 (2d ed. 2011).

61 Pub. L. 104-191, 110 Stat. 1936 (1996).

62 Standards for Privacy of Individually Identifiable Health Information, 65 Fed. Reg. 82461 (2000).

63 45 C.F.R. §§ 160.102(a), 160.103.

64 45 C.F.R. § 160.103.

HIPAA隱私規則肯定個人原則上有權接近，以檢視其在「指定紀錄集」(designated record set)中的受保護健康資訊與獲得副本⁶⁵。所謂指定紀錄集，被定義為「一組由被涵蓋機構所保存或為被涵蓋機構而保存之紀錄，且為(i)由被涵蓋之醫療照護提供者所保存或為被涵蓋之醫療照護提供者而保存之關於個人的醫療紀錄或帳單紀錄，(ii)由健康計畫所保存或為健康計畫而保存之登錄、付款、請求裁決、案件或醫療管理紀錄系統，或(iii)全部或部分由被涵蓋機構用於或為被涵蓋機構而用於作成有關個人之決定。⁶⁶」在上述條款之連結理解下，若研究沒有治療的成分，而個別研究結果既不成為參與者醫療紀錄的一部分，也不被研究機構用於作成與個人有關的決定，係純粹貢獻於一般性知識的產生，則該個別研究結果雖與參與者個人有關，但因並非指定紀錄集的一部分，參與者並無權請求近用⁶⁷。雖然大部分研究可能落入上述情形，但HIPAA隱私規則為「包含治療之研究」創設了接近權例外條款，透露出研究脈絡下仍存在可主張接近權的情境。具體而言，像是醫院A招募其病患B參與針對所患疾病之新藥的臨床試驗，即屬所謂「包含治療之研究」⁶⁸。此一臨床試驗所產生的資料，有可能成為B醫療紀錄的一部分，且也有可能關涉作成對B之在試驗中或醫療中的決定；若然，即落入指定紀錄集範疇中，而可成為B請求近用的標的。然而，若一律允許個人近用此類研究中的健康資料，可能對研究造成阻礙。舉例來說，在試驗進行中，若B請求揭露其所用藥物係試驗中新藥或安慰劑，而得知相關資訊時，將影響其心理狀態而造成實驗偏差。因此，HIPAA隱私規則創設了一項例外規定，基本上允許在包含治療之研究中所創造或取得之受保護健康資訊，於研究進行

65 45 C.F.R. § 164.524(a)(1).

66 45 C.F.R. § 164.501.

67 See NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, CLINICAL RESEARCH AND THE HIPAA PRIVACY RULE, NIH Publication Number 04-5495, at 15 (2004), https://privacyruleandresearch.nih.gov/pdf/clin_research.pdf.

68 See *id.*

中可暫停受個人之接近請求，但前提是個人於同意參與研究時，已理解並同意沒有接近請求權，且受涵蓋之健康照護提供者已告知該個人，其接近權會在研究結束時被恢復⁶⁹。簡言之，該規則認可在研究脈絡下，個人之接近權可以特別約定的方式排除，但僅限於研究進行中，於研究結束後，個人仍有權接近取得。舉例來說，假設醫院A招募其病患B參與一項臨床試驗，A在該試驗之告知後同意書中，表明參與者對研究所產生之健康資料的接近權，在研究進行中將暫停，並於研究結束後恢復，而獲得B之同意。則在該試驗進行中，B向A請求取得與其有關之研究發現時，A得予拒絕；但在試驗結束後，A即無拒絕B之請求之餘地。另外，若A未於研究之告知後同意程序中與B約定排除接近權者，即使在試驗進行中亦不得拒絕B之請求。

前引不同立法例在生醫研究脈絡下接近權之賦予與排除上的界線，可以下表1來呈現。比較起來，在接近權之建立上，歐盟資料保護一般規則與英國1998年資料保護法廣開大門；美國HIPAA隱私規則則相當限縮，在不涉醫療環境且與作成涉及個人之決定無關的研究，基本上即無接近權之享有。在例外排除的要件部分，各立法例之設計頗為分歧。歐盟資料保護一般規則要求對研究造成嚴重阻礙的相當可能性，似乎是一個偏向嚴格的標準。英國1998年資料保護法設定了三項要件，但仔細來看，許多研究可能都可以符合。美國HIPAA隱私規則之規範模式，則是不以特定情境條件為要件，而委諸個人之自主決定，也就是以個人是否同意為前提，同時，僅允許暫停接近權，於研究結束後須予恢復；分析起來，雖然取得個人同意，是相對容易達成的門檻，但另一方面，研究者並無法完全排除接近權，而僅能限制行使之時間而已。

69 45 C.F.R. § 164.524(a)(2)(iii).

表1 三項立法例於生醫研究脈絡下接近權規定之比較

立法例	接近權之賦予	於研究脈絡之例外排除
歐盟資料保護一般規則	全面性賦予	相當可能使得研究目的無法達成或造成嚴重阻礙；且具備本規則要求之「適當之保護措施」
英國1998年資料保護法	全面性賦予	該資料並非為支持有關特定個人之措施或決定而處理； 該資料並不以會造成資料主體實質傷害或實質痛苦之方式處理；且 研究結果或任何產生之統計，不以可辨識資料主體之方式呈現
美國HIPAA隱私規則	僅針對「指定紀錄集」中受保護健康資訊賦予	個人於同意參與研究時，對於接近請求會遭受拒絕已表示同意；且 受涵蓋之健康照護提供者已告知該個人，其接近權會在研究結束時被恢復

資料來源：作者製表。

綜合上述之觀察，可以發現近用與研究之調和，呈現出不同的法制政策選擇。為研究創設個人接近權之例外條款，是政策上可能，而實際上亦已存在於其他法域之選項。此種法制對個人接近權有所減損，但留下較大的彈性空間，讓當事人、倫理規範與倫理機制等有多一些發揮的餘裕。相對於前述比較法的例子，我國法制則落在政策光譜的另外一端，也就是並未針對研究創設例外條款的情形。以下將回到我國法下，深入探討個別研究結果之近用的法律解釋適用。

二、我國法規範概覽

（一）憲法基礎

在進入法律層次的觀察前，值得先從憲法層次，探究個人資料接近權的基礎，以作為支撐與理解法律規範的前提。在司法院大法

官作成司法院釋字第603號解釋前，學說上已為個人資料保護的權利基礎，提供了豐富的論述⁷⁰。在司法院釋字第603號解釋出爐後，此一權利概念更非僅只於學說所承認，而係明確成為憲法秩序的一環。

司法院釋字第603號解釋已將對個人資料之接近，納入憲法保護的範疇。該解釋提到：「隱私權雖非憲法明文列舉之權利，惟基於人性尊嚴與個人主體性之維護及人格發展之完整，並為保障個人生活私密領域免於他人侵擾及個人資料之自主控制，隱私權乃為不可或缺之基本權利，而受憲法第二十二條所保障（本院釋字第五八五號解釋參照）。其中就個人自主控制個人資料之資訊隱私權而言，乃保障人民決定是否揭露其個人資料、及在何種範圍內、於何時、以何種方式、向何人揭露之決定權，並保障人民對其個人資料之使用有知悉與控制權及資料記載錯誤之更正權。」基此，資訊隱私權為隱私權此一基本權利的一部分，以憲法第22條概括條款為依據而受保障。資訊隱私權的內涵，即個人對其個人資料之自主控制，除了表現在與個人資料揭露有關之面向的決定權外，亦涵蓋對個人資料的接近、掌握與更正的權利。在此理解下，本文所關注的個人資料接近權，並非僅倚賴立法者的恩賜，而是被涵蓋在受憲法保障的權利範圍內。個資法對個人資料接近權的相關規定，係對於憲法指引的體現與落實。

70 例如李震山，論資訊自決權，收於：李鴻禧教授六秩華誕祝賀論文集編輯委員會編，現代國家與憲法——李鴻禧教授六秩華誕祝賀論文集，頁709-756（1997年）；黃昭元，無指紋則無身分證？——換發國民身分證與強制全民捺指紋的憲法爭議分析，收於：國際刑法學會台灣分會編，民主、人權、正義——蘇俊雄教授七秩華誕祝壽論文集，頁461-507（2005年）；李建良，「戶籍法第八條捺指紋規定」釋憲案鑑定意見書，台灣法學雜誌，73期，頁41-44（2005年）；陳起行，資訊隱私權法理探討——以美國法為中心，政大法學評論，64期，頁297-341（2000年）。

個人資料接近權雖被我國釋憲實務納入資訊隱私權的範疇內，但究其本質，乃是一項工具性的權利，其目的在促進資訊隱私的盡可能實現。學說上對於資訊隱私權/資訊自決權，向來以個人資料之向他人傳遞/揭露的自主決定為中心來加以界定，在概念上並不直接包含向資料控制者接近的權利⁷¹。此從隱私權保障的根本價值來看，亦可得到印證。隱私權的核心利益，是在保障個人不被過度暴露於外而受他人侵擾、品評的心理感情⁷²。而接近權的存在與

71 See, e.g., ALAN F. WESTIN, *PRIVACY AND FREEDOM* 7 (1967) (“Privacy is the claim of individuals, groups, or institutions to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others.”); R. A. GLENN, *THE RIGHT TO PRIVACY: RIGHTS AND LIBERTIES UNDER THE LAW* 205 (2003) (quoting Westin’s definition); DANIEL J. SOLOVE, *THE DIGITAL PERSON: TECHNOLOGY AND PRIVACY IN THE INFORMATION AGE* 76 (2004) (quoting Westin’s definition and noting that “[n]umerous other scholars embrace this definition.”); DANIEL J. SOLOVE & MARC ROTENBERG, *INFORMATION PRIVACY LAW* 1 (2003) (“Information privacy concerns the collection, use, and disclosure of personal information.”); C. Edwin Baker, *Autonomy and Informational Privacy, or Gossip: The Central Meaning of the First Amendment*, 21(2) *SOC. PHIL. & POL’Y* 215, 217 (2004) (“informational privacy could refer at least to the following: *information inalienability, disclosure control, and dissemination control.*”); RICHARD C. TURKINGTON & ANITA L. ALLEN, *PRIVACY LAW: CASES AND MATERIALS* 77 (2d ed. 2002) (“‘Informational Privacy’ is a shorthand expression that will be used throughout these materials to identify that factual condition in life that embodies concern about limiting acquaintance with personal affairs.”); GRAEME LAURIE, *GENETIC PRIVACY: A CHALLENGE TO MEDICO-LEGAL NORMS* 6 (2002) (“privacy can be seen as a state in which personal information about an individual is in a state of non-access from others – *informational privacy.*”); 林子儀，基因資訊與基因隱私權——從保障隱私權的觀點論基因資訊的利用與法的規制，收於：翁岳生教授祝壽論文集編輯委員會編，*當代公法新論*（中冊）——翁岳生教授七秩誕辰祝壽論文集，頁701（2002年）（「一個人可以自行決定何時、以怎樣的方式，將那些有關個人的資訊公開給誰的權利。」）；李震山（註70），頁710（「所謂『資訊自決權』，係指每個人基本上有權自行決定，是否將其個人資料交付與供利用。」）；李建良（註70），頁42（「人民在憲法上享有決定何時、於何等範圍內公開或提供其個人專屬資訊，或使他人得以進入或接觸專屬其個人資訊領域之權利。」）；李惠宗，*憲法要義*，6版，頁383（2012年）（「資訊自決權係指個人基本上有權自行決定是否將其個人資料，包括住址、身分、血型、財產、家庭關係、健康、基因（DNA）等資訊，交付與提供利用之權利，更精確地說應是『個人資訊自決權』。」）。

72 參照陳仲嶼，隱私權概念的理解與充填，收於：李鴻禧等著，*台灣憲法之縱剖*

否，並不直接關涉個人向外界封閉或開放程度的心理感情，因此自非資訊隱私保障的本質內涵。但是，倘若吾人無法知悉有那些資訊被他人掌握、進行如何之處理與利用，以及該等資訊是否正確，將不易確知他人對自己個人資料的利用是否逾越可接受的範圍而傷害到隱私感情。因此為使資訊隱私獲得更大程度的實現，接近權應予肯認，並由立法者事先架構完善之制度⁷³。

接近權作為一項附隨性、工具性的權利，在決定其所受保障程度與審查密度時，似應獨立於資訊隱私權核心部分之外，而給予不同的思考。關於資訊隱私權與違憲審查標準的連結，司法院釋字第603號解釋提供了有價值的分析架構。該號解釋理由書中提到，應「就所蒐集個人資訊之性質是否涉及私密敏感事項、或雖非私密敏感但易與其他資料結合為詳細之個人檔案，於具體個案中，採取不同密度之審查。」這意謂著，並非所有限制資訊隱私權的國家行為均觸發相同的審查標準；而在決定應適用的審查標準時，有二項值得考慮的因素，一是所涉資訊的私密敏感程度，一是與其他資料結合為詳細個人檔案的可能性。標的資訊愈是私密敏感，或愈是容易發生與其他資訊連結而呈現個人圖像者，愈是應給予高密度的審查⁷⁴。如前所述，隱私權的核心利益係在保障個人不被過度暴露於外而受他人侵擾、品評的心理感情；而資訊隱私權——對個人資料的自主控制——作為隱私權之一環，也很自然主要是在期望避免，個人資料的不當利用揭露欲求隱藏的一面或過度地暴露自己。因此，當標的資訊高度私密敏感或有高度可能性呈現個人的圖像時，

橫切，頁637-661（2002年）。一個脈絡式思考而可突顯隱私保障核心價值的案例分析，參照葉俊榮，探尋隱私權的空間意涵——大法官對基本權利的脈絡論證，中研院法學期刊，18期，頁30-33（2016年）。

⁷³ 參照李震山（註70），頁739。

⁷⁴ Chung-Lin Chen, *In Search of a New Approach of Information Privacy Judicial Review: Interpretation No. 603 of Taiwan's Constitutional Court as a Guide*, 20 IND. INT'L & COMP. L. REV. 21, 37-39 (2010) (noting the two factors identified by Interpretation No. 603 and other potential factors that should be considered).

就代表存在高度的隱私風險，而值得司法者審慎的關注。就此而言，司法院釋字第603號解釋所揭示的審查密度判定準則，確有其洞見。不過，此一判定準則是否完全連動到有關個人資料接近權之違憲審查，尚待思索。舉例來說，當國家欲蒐集、使用或揭露高度私密敏感之人民個人資料時，須受到司法的嚴格檢視，已無疑問；惟在此同時，對於國家已取得之高度私密敏感個人資料，限制個人之接近權，是否必然須受相同嚴格的審查，則仍欠缺討論，本文亦未敢遽下斷語。因與後文無直接關聯，暫且留待未來再做探索。

（二）法律規範

我國對於個人資料的接近權，已透過個資法全面性地賦予個人。個資法第10條本文規定：「公務機關或非公務機關應依當事人之請求，就其蒐集之個人資料，答覆查詢、提供閱覽或製給複製本。」明確建立個人就其個人資料之接近權。雖然同條但書設有例外規定，排除下述三種情形之權利行使，包括「一、妨害國家安全、外交及軍事機密、整體經濟利益或其他國家重大利益。二、妨害公務機關執行法定職務。三、妨害該蒐集機關或第三人之重大利益。」但並無針對研究所設之排除條款。

個資法同時建置了許多配套規範。例如個資法第13條第1項規定：「公務機關或非公務機關受理當事人依第十條規定之請求，應於十五日內，為准駁之決定；必要時，得予延長，延長之期間不得逾十五日，並應將其原因以書面通知請求人。」設下了決定時程的限制，以避免接近權之行使遭受遷延擱置以致無法實現。另外，個資法第14條規定：「查詢或請求閱覽個人資料或製給複製本者，公務機關或非公務機關得酌收必要成本費用。」將費用限制在必要成本範圍內，以避免藉高額收費阻礙權利行使，同時也提供收取費用的依據，衡平接近權機制對於保有個人資料者之負擔。此外，個資法第3條規定，當事人就其個人資料之接近權，「不得預先拋棄或以

特約限制之」，以確保該等權利不致在契約自由的名目下遭到架空。

除個資法的一般性規定外，規範生醫研究之法律是否存在與接近權有關之條款，亦值得注意。首先，我國針對生醫研究管制立有一項專屬法律，即人體研究法。不過，該法中並未訂定任何與接近權有關之規定。其次，針對生物資料庫型態之研究，另有人體生物資料庫管理條例作為特別法，該法中與接近權有關之條款值得注意。人體生物資料庫管理條例第10條提到：「依本條例所為之生物檢體或資料、資訊之蒐集、處理，參與者不得請求資料、資訊之閱覽、複製、補充或更正。但屬可辨識參與者個人之資料者，不在此限。」依此，除可辨識參與者個人之資料外，參與者請求接近研究資料的權利受到排除。

將上述規範適用於本文探索之議題——生醫研究脈絡中參與者對個別研究結果之接近，浮現出幾個法律解釋上的議題，有待深入分析。第一，個資法第10條之得請求範圍，是否包含研究者自行產製而得之個人資料？第二，人體生物資料庫管理條例第10條與個資法第10條，二者規範內涵之關係為何？第三，告知同意書中就接近研究資料所為之內容，產生何等效果？以下分述之。並於其後進一步呈現個資法接近權規定於個別研究結果提供上之具體操作。

三、請求個別研究結果上的解釋適用問題

（一）控制者自行產製之資料的近用

個資法第10條明確建立了，個人向個人資料蒐集者請求接近其個人資料之法律基礎。存有疑問的是，條文的規定是，蒐集者應「就其蒐集之個人資料」答覆查詢、提供閱覽或製給複製本；文義上似有可能解釋為，蒐集者僅就其向個人蒐集得來之個人資料有提供接近的義務，而就蒐集者自行產製而得的個人資料，無須提供。

具體舉例而言，基因檢驗的結果，並非研究者從參與者處蒐集而來，而是以參與者所提供之檢體與資料為材料，進一步藉由專業技術方法生產之新的資料。即使該等資料因仍具識別性而構成個人資料，研究者得否主張並非「其蒐集之個人資料」，而拒絕提供？

首先，對個人資料接近權內涵之理解，可從憲法保障之資訊隱私權談起。如前所述，依司法院釋字第603號解釋之闡釋，個人資料之接近權，係體現個人對其個人資料自主控制的權利——也就是資訊隱私權——之一環。而個人資料之自主控制的概念，表徵著個人應有權知悉與控制他人對其個人資料之使用。由此推論，只要是其個人資料，個人即應有權接近知悉。至於個人資料的產生來源——係個人所提供或使用者自行生成——似不具重要性。甚至，非由個人提供之個人資料，個人更有需求請求知悉，因其無從透過自己的回憶或紀錄中去得知何等資料正被掌握與處理。

其次，比較法亦可提供借鏡。前引歐盟、英、美法制，似均未區分個人資料係向個人蒐集而來或由控制者自行產製，而異其接近權規範。從美國HIPAA隱私規則中，甚至可以明顯看到個人得接近之健康資訊，包含受規範主體所「創造」者⁷⁵。因此，倘若將個資法第10條之請求客體，解釋為「僅及於蒐集者向個人蒐集而來之個人資料」，將使我國法制成為國際間的異例。

第三，從法務部有關病歷之函釋來推論，現行行政實務之見解對於個資法第10條之解釋，似亦肯定個人之接近標的包含由使用者產生出來的個人資料。蓋病歷中之資訊，必然包含非由病人所提供，而係經由醫師之專業判斷所產生的個人資料；而法務部並未因此將該等個人資料區分出來，而否定個人得依個資法請求近用。首先，法務部102年3月12日法律字第10100271950號函明確表示，病

75 參照前註64至66之附隨本文。

患得依個資法規定向醫療機構申請閱覽其本人之病歷資料，除有構成個資法第10條所列例外情形（例如病歷有遭受毀損、滅失、塗改或散佚之虞而無其他方法防止等妨害該蒐集機關之重大利益之情形，可構成該條第3款之例外事由）外，醫療機構應提供閱覽，且不得以製給複製本代替提供閱覽。後於法務部102年7月4日法律字第10200118830號函再次重申前函意旨，並表示「病人申請閱覽自己病歷資料之權利，屬於個人自主控制個人資料之資訊隱私權之範疇，是以，國家僅得於符合憲法第23條規定意旨之範圍內，以法律明確規定對之予以適當之限制。」該函並強調，雖然醫療法第71條有「醫療機構應依其診治之病人要求，提供病歷複製本，必要時提供中文病歷摘要，不得無故拖延或拒絕；其所需費用，由病人負擔。」之規定，但並未限制閱覽病歷之權利，醫療法無閱覽病歷規定，病患自得依個資法請求閱覽。由上可知，法務部並未因為許多病歷資料係由醫療人員專業判斷或檢驗而產出，即認為不在個資法第10條得請求的範圍內。

綜上所述，從個人資料接近權之憲法基礎、比較法與個資法目前之解釋實務來推導，可知主張本條僅適用於自個人蒐集而得之個人資料，並無法得到支持。對於研究者自行產生之個別研究結果，參與者應得依個資法第10條請求答覆查詢、提供閱覽或製給複製本。

（二）生物資料庫脈絡的法律適用關係

第二項值得探討的議題是，人體生物資料庫管理條例第10條與個資法第10條，二者規範內涵之關係。此一議題涉及到在生物資料庫的脈絡下，生物資料庫參與者得否向生物資料庫請求接近個別研究結果之問題。由於人體生物資料庫管理條例第10條對於接近權有專門規定，依特別法優先於普通法之適用原則，乍看之下，似可排除個資法第10條。然而，二個條文間是否真的存在衝突而有適用先

後問題？或其實架構於一致性的法秩序？值得從條文內涵進一步探索。

人體生物資料庫管理條例第10條本文表示，參與者原則上不得請求資料或資訊之閱覽與複製；不過，但書將「可辨識參與者個人之資料」排除於不得請求之範圍外。換句話說，參與者若有請求基礎，非不得請求「可辨識參與者個人之資料」。而根據個資法第2條的定義，任何「得以直接或間接方式識別該個人之資料」即屬個人資料，因此，人體生物資料庫管理條例第10條但書所描述之標的，似即等同於個資法個人資料之概念。這也意謂著，人體生物資料庫管理條例第10條在關於個人接近權上，與個資法之意旨一致，並未排除任何個資法所承認之權利，其完整意涵為：參與者對生物資料庫之資訊、資料，除其個人資料外，無請求閱覽、複製、補充或更正之權利；至於對其個人資料，仍回歸個資法所賦予之權利。

值得一併探究的是，人體研究法在接近權上保持沉默，法解釋上意涵為何？是否有可能解為，在人體研究脈絡下不賦予參與者接近權之意？本文以為，在人體研究法未訂定排除或相衝突規定的情況下，其他法律所賦予之權利，參與者自得享有。蓋人體研究法並未採取重新臚列所有參與者權利之模式，而僅於第6條與第14條分別針對研究計畫與告知事項內容，概括地指明應包含「研究對象之權益」，連結了參與者所有既有的權利和利益。因此個資法之接近權自然也應在人體研究的脈絡下受肯認。

綜上，雖在生物資料庫之脈絡，有人體生物資料庫管理條例此一特別法存在，但就其具體規定而言，係與個資法架構在一致性的法秩序下，並未排除任何個資法已肯認的權利。基此，參與者對生物資料庫，仍得依個資法規定行使其接近個別研究結果的權利。

(三) 同意書內容對接近權的影響效果

最後有待分析者，係告知同意書中就接近研究資料所為之內容，是否產生何等效果之議題。如前所述，衛生福利部所發布之「人體生物資料庫參與者同意書參考格式」第十一點「排除之權利」項下之文字，明白否定通知參與者個別研究結果之可能，甚至在參與者主動要求取得時，也採取拒絕立場⁷⁶。倘若各生物資料庫遵循衛生福利部之建議來撰寫參與者同意書，參與者之接近權是否即受排除？

依據個資法第3條，答案很明確是否定的。如前曾提及的，為防免在契約自由的名目下遭空洞化，該條規定參與者之接近權，「不得預先拋棄或以特約限制之」，明白確立其強行規定之地位。因此，即使在同意書中約定不提供檢驗結果，約定也屬無效。衛生福利部之參考格式著重於研究利益之保障，但沒有注意到個資法將個人接近權確立為強行規定，無法透過個別約定來排除。考系爭參考格式的性質，因非採行政命令之形式，且名稱上已明白宣示為供「參考」之用，顯屬不具法效性之事實行為。雖然該事實行為之對象——也就是所有現在與未來之人體生物資料庫設置者——不具特定性，不符合行政指導之定義⁷⁷，因而不受行政程序法行政指導相關規定之拘束，但所有行政行為包括事實行為在內，均應受法律與一般法律原則之拘束⁷⁸，系爭參考格式不能牴觸個資法之規定，自屬當然。

76 參照前註40之附隨本文。

77 行政程序法第165條規定：「本法所稱行政指導，謂行政機關在其職權或所掌事務範圍內，為實現一定之行政目的，以輔導、協助、勸告、建議或其他不具法律上強制力之方法，促請特定人為一定作為或不作為之行為。」（粗體為本文所加。）非針對特定人，而以一定範圍內國民為對象或一般性公告周知性質之警告、提示、建議等的消息提供或溝通行為，學理上有以「通報」此一事實行為為下之類型概念稱之。陳春生，事實行為，收於：翁岳生編，行政法（下冊），3版，頁6-7（2006年）。系爭參考格式應屬此種類型之事實行為。

78 行政程序法第4條。

另值得附帶論及的是，衛生福利部所發布之「人體生物資料庫參與者同意書參考格式」中，並未包含告知依個資法第3條規定得行使之權利及方式，是否符合個資法規定，似有疑問。按個資法第8條規定，蒐集者向當事人蒐集個人資料時，原則上應告知當事人所列六款事項，其中包括第5款的「當事人依第三條規定得行使之權利及方式。」雖然人體生物資料庫管理條例第7條亦有告知事項之規定，但似不應解為有排除個資法適用之意。因此，該參考格式內容是否妥適，似宜檢討。

（四）請求之具體操作

前述之分析顯示了，只要不存在個資法第10條之例外情形，生醫研究中之參與者基於個資法第10條而產生之對個別研究結果的接近權，並不因所涉資料非由參與者提供的性質、人體生物資料庫管理條例的特別規定，或同意書中的排除約定等因素，而有改變。然而，個資法第10條並非針對個別研究結果的請求而設，在立法時也無由意識到此一情境脈絡，則當本條運用於此一情境脈絡時，究竟體現出如何之具體面貌？例如，參與者得藉本條提出如何之請求？研究者接獲請求時，又應如何回應以符合本條之要求？在生物資料庫的情形，又與一般研究有何不同？當研究者未遵循規定提供資料時，法律效果為何？

首先，請求之構成要件，很單純地聚焦於是否以請求者之個人資料為標的。也就是說，只要是參與者之個人資料，參與者即有權請求，而研究者即有義務提供。資料對參與者是否具有臨床價值、資料本身是否具備分析有效性、參與者對資料是否有足夠的理解能力等，均非所問。請求標的是否構成參與者之個人資料，是唯一的標準。另一方面，研究者有義務交付者，亦僅其所掌握之請求者的個人資料。研究者並無義務就該等資料提供額外說明，亦無義務挖掘或生產尚不存在或非在其控制中的資料。上述理解除了是法條文

義的自然解讀，也是個資法接近權制度係以個人對其個人資料之自主控制為核心理念下，理所當然的推論結果。

其次，費用收取的配套規定，亦是完理解請求適用上重要的一環。個資法第14條建立被請求者收取費用之法律依據，同時，當中使用「必要費用」之概念彰顯限縮收取費用於必要範圍之意旨。因此，研究者不致因為接近權制度而承擔過度之不利益，但亦不得恣意定價獲取額外收益，而僅得以確認標的、檢索資料、準備提供等工作之成本，作為計算費用之準據。另一方面，參與者在決定是否提出請求時，亦須意識到獲取資料伴隨著成本，而將支付的代價納入考量。

第三，個資法之接近權規定雖未設研究例外，但並不排除某些研究情狀落入其一般性例外條款範圍內的可能性。特別是個資法第10條所列三項例外當中的「妨害該蒐集機關或第三人之重大利益」，或有可能於揭露資訊將嚴重損害研究進行時，成為研究機構拒絕接近請求的依據。不過，由於該等例外條款畢竟非針對研究而設，文句又極為概括不確定，具體適用時恐有相當困難。例如，倘若在臨床試驗中允許參與者獲知其位於實驗組或對照組之資訊，將導致實驗偏差。此種情形似有可能解為構成妨害研究機構之重大利益，惟亦仍留存爭論空間。

第四，請求規範於生物資料庫研究型態之適用，亦值得探究。生物資料庫本身可能作為研究資源之基礎設施，提供生物樣本與資料予次級使用之研究者進行研究。而當參與者依個資法規定向採樣之生物資料庫請求近用資料時，生物資料庫應提供之資料範圍為何？詳言之，此一應提供之資料範圍及於生物資料庫本身產生之個別研究結果，固無疑問，然是否及於次級使用者產生之個別研究結果，則有待進一步分析。依文義與目的解釋，參與者得依法請求之範圍，應僅及於被請求人所掌有之個人資料。由於生物資料庫與次

級使用者為不同主體，而次級使用者產生之個別研究結果，並不在生物資料庫的掌握中，因此，次級使用產生之研究結果應解為不在生物資料庫提供義務範圍內。另從政策觀點視之，倘若提供範圍及於釋出後衍生資料，生物資料庫在接獲請求後，必須例外地進行識別性作業，找出那些釋出案包含該參與者之檢體與資料並連繫次級使用者，因而可能增加隱私風險；尤其是在生物資料庫與次級使用者未預先有所準備、未建立標準作業流程，因偶然接獲參與者請求而行動時。且由於生物資料庫可能釋出予多數研究者，接受釋出之研究者亦可能以該去識別性之檢體與資料持續進行多數研究，甚至與其他研究者合作或提供其他研究者進行研究，如果這些研究結果之追索均在生物資料庫之義務範圍內，將延伸廣泛而欠缺合理界限，對生物資料庫恐形成過度負擔。故若將其去識別化釋出後所衍生資料之提供也解為生物資料庫之義務，似非合於妥善政策考量之解釋。當然，生物資料庫仍可在審慎考慮後，對於接獲請求後之機密性保護作業流程、與次級使用者之關係等面向均妥善規劃下，於法律義務之外，採取提供次級使用衍生資料的政策。

然而有疑問的是，次級使用者若為生物資料庫之設置者的所屬成員，是否影響上述解釋？也就是生物資料庫——實際上是生物資料庫之設置者——之提供義務，是否及於設置者所屬次級使用者研究產生之個別研究結果？例如研究機構A設置一生物資料庫，機構內研究人員B和機構外研究人員C均申請取得生物資料庫之檢體與資料進行研究，對於B和C之研究，A之提供義務是否不同？本文認為，雖然生物資料庫設置者所屬成員進行之研究，有解為生物資料庫設置者之研究的可能，以致其研究結果被解為落入提供義務範圍內，但此種形式化的理解，將造成同屬次級使用者，機構內、外研究人員差別對待之結果。此種差別對待，似與人體生物資料庫管理條例之規範精神未盡一致。蓋在人體生物資料庫管理條例下，生物資料庫受主管機關與倫理委員會之高度管制，在隱私/機密性保護

上並有嚴密規範，依其制度精神，生物資料庫不論釋出樣本與資料予誰，對於原本去識別性狀態之破壞，都應該遵循同等的理由標準。由於當生物資料庫向次級使用者索取關聯特定參與者之研究結果時，可能增加之隱私風險，在釋出予機構內、外研究人員之情形，並無不同。基此，若機構外之次級使用者的研究結果被解為不在提供義務範圍內，機構內之次級使用者的研究結果，似亦應獲得相同解釋。

第五，倘若研究者未遵循個資法之規定，法律效果如何？首先，個資法第48條賦予了行政罰之法律效果，對違反第10條規定者，「中央目的事業主管機關或直轄市、縣（市）政府限期改正，屆期未改正者，按次處新臺幣二萬元以上二十萬元以下罰鍰」。其次，除了仰賴行政機關之行政罰加諸的強制力外，參與者亦可透過司法程序來直接達成獲取資料之目的。蓋有權利必有救濟，個資法第10條既明定了接近權，自可藉由司法程序來實現。於被請求者為非公務機關之情形，當事人得以接近權為請求權基礎，提起民事訴訟，請求法院判令該非公務機關給付。於被請求者為公務機關之情形，當事人亦得以接近權受侵害為基礎，提起行政爭訟，請求行政法院判令該公務機關作成准許接近資料之處分⁷⁹。

為了讓前述仍屬抽象的法條詮釋有更鮮活的面貌，以下將以二個假設案例呈現請求與回應的可能運作。

案例一：大學教授A之研究團隊進行一項癌症研究，在招募參與者之說明同意書中表示，將採集不同年齡層及性別之健康參與者的血液樣本，分析目前醫學報導確定的癌症腫瘤基因，觀察建立國人該等基因突變之出現頻率，並探究作為癌症檢測方法基準值之可能。B參與了此項研究，並基於說明同意書中之內容，一直對其血

⁷⁹ 行政訴訟之實際案例可參照臺灣臺北高等行政法院106年度訴字第865號判決。

液樣本之檢驗結果存有高度好奇。一年後其以個資法第10條為依據，向A請求提供其癌症腫瘤基因之檢驗結果。A於其研究資料中找出B之檢驗結果，提供給B，但當中僅有許多不包含任何解釋的數值。B無法了解該檢驗結果之意涵，但A表示這是其所有有關B的資料，因為這些研究資料並非以醫療檢測為目的製作，不能以醫療檢測之標準來看待。

案例二：研究機構C蒐集大量健康人之血液檢體與資料，設置一大型生物資料庫。於招募參與者階段，會對參與者進行特定身體檢查，包括膽固醇、高密度膽固醇、三酸甘油脂、尿酸、尿素氮、肌肝酸、肝功能檢驗與肝炎病毒指標等之血液檢驗，以及肺功能、骨密度等之基本身體檢測。其後累積之檢體與資料，開放機構內、外之研究人員申請使用。D為參與者之一，二年後於新聞報導中看到，數個研究團隊利用C之生物資料庫中的材料，在不同的疾病研究上有所突破，引發其高度興趣。D向C提出請求，欲獲取當初身體檢查的檢查結果，以及後續所有研究針對其個人之檢體與資料分析之結果。C向D提供了身體檢查之報告，但表示該生物資料庫中，並不包含檢體與資料釋出後所進行研究的資料，故就「後續所有研究針對其個人之檢體與資料分析之結果」部分，尚難辦理；另外，該生物資料庫刻正規畫針對部分參與者之檢體進行全基因體定序，但因尚未實施，故目前亦無資料可以提供。

如上所示，個資法之接近權制度，確實為參與者接近取得個別研究結果提供了法律上的基礎。費用收取的配套規定，產生某程度兼顧研究者成本的效果。適用於生物資料庫研究型態時，若採特定解釋，亦不致過度膨脹法律義務負擔。然而，個資法之接近權有其原本的制度目的，運用在提供個別研究結果的脈絡，是否契合事物本質而得以帶來理想的結果，仍有待深思。

四、法制現況之反思

個別研究結果的是否提供以及如何提供，涉及許多考慮因素，而個資法基於其以個人對其個人資料之自主控制為支配性價值，所建構的接近權制度，是否能與之相契合，從前述法律操作的呈現嘗試，已可隱隱然令人感到疑問。雖然系爭接近權規定亦存在例外條款，但非針對研究所設，在文句高度概括模糊的情況下運用於研究脈絡，不僅適用空間有限，也欠缺可預測性。因此，藉著提供個別研究結果之議題，就我國相對其他國家對研究較不留餘地的接近權法制，或可開啟一些反省。

事實上，從整體來觀察，個人資料保護法制對於個人資料在研究上的運用，原本便存在不同於其他運用脈絡的規則。或者可以說，個人資料保護法制設有研究例外規定，讓研究在特定條件下得以免於一般性規則的拘束。舉例來說，我國個資法第16、19、20等條文，均將符合特定條件的研究，納為允許個人資料之蒐集、處理與目的外利用的情形之一。而不論是歐盟資料保護一般規則、英國1998年資料保護法、美國隱私權法或HIPAA隱私規則，都為研究建置了細緻化的例外條款⁸⁰。這些研究例外設計之存在，有其道理。首先，研究以追求知識為目的，進而貢獻於促進社會福祉之公共利益，向來被認為係具有高度價值之人類活動，而該活動又極度仰賴資料的獲取與分析⁸¹。因此，相較於其他以追求私益為目的之活動

80 關於各該國家法規之研究例外規定的詳細介紹，可參照賴羿慈，個人資料保護法制中研究例外規定之比較分析，國立清華大學科技法律研究所碩士論文，頁74-79、82-86、88-91、93-106（2017年）。

81 例如最高行政法院便曾於健保資料庫案（探討全民健康保險研究資料庫與健康資料加值應用協作中心之建置，以供學術研究之用，是否有違反個人資料保護法之處）中提到，「全體國民之身體、健康、疾病及就醫等宏觀資料，對健康政策之擬定，與疾病之預防與治療均有重大意義，此等資料之處理具有『重大公益目的』實甚明確……全體國民之身體、健康、就醫等宏觀資料，對國家衛生福利之增進，有重大意義，而具高度之公益性。且其蒐集困難，一旦搜集而得，應給予充分利用之機會，以增進社會整體福利。」最高行政法院106年度

如商業活動，具有正當性被給予較多的迴旋空間。其次，研究以生產可普遍化之知識（generalizable knowledge）為目的⁸²，因此個人資料僅在研究過程中有意義，研究者並無誘因揭露資料主體之識別性。此與其他以追求私益為目的之活動如商業活動，存在經濟誘因將個人資料盡可能進行交換，以及具有必要性以識別性的狀態使用資料以達成針對個人之行銷與交易，有所不同。因而研究對資訊隱私的潛在風險，相對較低。第三，針對研究活動向來已發展出許多個人資料保護法制以外的治理規範或機制，包括研究倫理規範與研究倫理審查機制等，這些治理力量也都會在保護資訊隱私上發揮作用⁸³。在其他以追求私益為目的之活動如商業活動，倫理規範之能量未臻成熟，也不受倫理審查機制之制約，研究活動與之相較，透過個資法制給予高度管制的的需求較低。

針對個人資料之接近權，基於前述同樣的考量，也導向於支持某程度對研究給予例外規定的方向。甚至，透過本文所探討之提供個別研究結果脈絡下的省思，吾人更可覺察到，無限制的接近權運用於研究範疇時可能發生的不當結果與理念齟齬。例如在前文介紹美國HIPAA隱私規則時提及的臨床試驗之例，便突顯出接近權在某些情境會導致實驗偏差，破壞研究之科學性的結果⁸⁴。更值得省察的是，個別研究結果之提供在現有倫理指引與政策建議中被提出的標準，像是分析有效性、臨床重要性、臨床可行性與當事人同意等，背後所關注的不僅是對研究利益的兼顧，亦包含對參與者的福

判字第54號判決。

82 THE NATIONAL COMMISSION FOR THE PROTECTION OF HUMAN SUBJECTS OF BIOMEDICAL AND BEHAVIORAL RESEARCH, THE BELMONT REPORT, at Part A (Apr. 18, 1979), <https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/read-the-belmont-report/index.html>; 45 C.F.R. § 46.102(d).

83 關於專業倫理規範作為一種治理力量之制度優勢，可參照Chung-Lin Chen, *Reconciling Family Paternalism and Autonomy in Taiwan's Health Information Law*, AUSTL. J. ASIAN L. 247, 259 (2009).

84 參照前揭註69之附隨本文。

祉，因為將資料恣意傾倒予參與者，可能不但對其無益，反而造成傷害⁸⁵。雖然接近權由參與者發動，彰顯當事人取得資料的自主意願，但以個人資料之自主控制為支配性價值所預設的前提——獲得愈多資料對當事人愈有利，不盡然真確。雖然理論上，立法者可以在接近權制度中納入相關考量而為提供個別研究結果打造量身訂做的規範，但在相關考量複雜且高度個案取向，而對研究者應如何行動倫理學界亦仍莫衷一是的情況下，直接加諸以強制性的法律規範，恐難以契合個案實態，或至少時機未臻成熟。還不如仿照歐盟、英國與美國之立法例，對研究有條件地開設例外。因為如此一來，將自然容留研究者與研究倫理委員會納入相關考量，設計切合於所屬情境之提供近用政策的迴旋空間，似乎是更符合政策妥當性的法制方向。

或有認為，一旦解除提供接近的法律上義務，研究者即不會理會參與者之請求，基於其本身利益的考量，希望研究者自發地籌劃友善參與者近用的政策，乃屬期待不可能。雖然研究者的自利是支配其行動的重要力量，但也不應忽略正因為如此，研究社群發展出來的自律規範與機制，包括研究倫理規範與研究倫理審查機制，已有相當歷史也扮演著重要的制約角色⁸⁶。雖然提供個別研究結果之議題晚近才浮現，在倫理上的應然實踐仍未形成明確共識，但從本文第貳章第二節的觀察可以看到，研究倫理社群已極為嚴肅、積極地面對此項議題，假以時日，研究倫理委員會的約束，以及逐漸滲

85 完整的政策考量分析，請參照本文第肆章。

86 關於研究倫理規範與研究倫理審查機制之發展，*see, e.g.*, PAULA BODDINGTON, *ETHICAL CHALLENGES IN GENOMICS RESEARCH: A GUIDE TO UNDERSTANDING ETHICS IN CONTEXT* 15-18 (2012); Stanley Joel Reiser, *The Ethics Movement in the Biological and Health Sciences: A New Voyage of Discovery*, in *THE ETHICAL DIMENSIONS OF THE BIOLOGICAL AND HEALTH SCIENCES* 3, 3-18 (Ruth Ellen Bulger et al. eds., 2d ed. 2002); 劉靜怡，「以人為對象」的研究和研究倫理委員會——以美國法制下之「言論出版自由」與「思想研究自由」為論述核心，*中研院法學期刊*，3期，頁211-221（2008年）。

入成研究慣行的倫理法則，將有機會在法律留下的自由空間中構築得以契合個別情境、兼顧各方價值的治理面貌。此外也值得釐清的是，所謂研究例外，並不必然是「只要是研究，就排除接近權」的規範模式，而是可以為何種情狀之研究或在符合何種條件下方得構成例外，設定進一步的要件。透過條款的設計，可將保護參與者的考量納入，讓部分研究情境仍有接近權的享有。

至於例外條款要件的具體設計，因並非本文探討中心，尚非敢遽下結論。但綜合前引國外立法，可以看出在創設例外排除接近權時，有二個方向的前提要件值得考慮。第一是，該資料非用以作成有關特定個人之決定。此一前提要件之設定理由在於，若資料將用以作成針對個人之決定，就應讓個人有機會近用，才能在面對有關其個人之決定時有效維護自己的權益。在立法例上，除了英國1998年資料保護法中明白存在「該資料並非為支持有關特定個人之措施或決定而處理」之規定外⁸⁷，從美國HIPAA隱私規則對制定紀錄組的界定中也可看出類似意旨。蓋在HIPAA隱私規則下，僅有列入指定紀錄集之資訊可成為接近權的標的，而從指定紀錄集的定義中可以看出，其目的在涵蓋用以作成有關個人之決定的資訊⁸⁸，故反面觀之，其係將是否用以作成有關個人之決定，作為排除或賦予接近權之界線。第二項前提要件的設定方向，則是要求對個人資訊隱私存在或採取一定之擔保。蓋愈是消弭了資訊隱私的風險，愈是減少了賦予接近權的必要性。因此在英國1998年資料保護法中對接近權之排除，除前引「該資料並非為支持有關特定個人之措施或決定而處理」外，亦同時要求以「研究結果或任何產生之統計，不以可辨識資料主體之方式呈現⁸⁹」及「該資料並不以會造成資料主體實質

⁸⁷ Data Protection Act 1998, c. 29, § 33(1).

⁸⁸ NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE, *supra* note 1, at 267.

⁸⁹ Data Protection Act 1998, c. 29, § 33(4).

傷害或實質痛苦之方式處理⁹⁰」為前提。另外，在歐盟資料保護一般規則當中之接近權的研究例外條款，則是以採取「適當之保護措施」(appropriate safeguards)為前提要件，依該規定，「該等保護措施應確保技術與組織機制之存在——尤其在為追求尊重資料最少化原則之確保」，而具體之此類機制例如假名化(pseudonymisation)，或甚至完全去除識別性⁹¹；其規範意旨與前述英國法有共通之處。倘若未來立法變革朝向容許研究豁免於接近權之要求，上述二項前提要件之方向，或許是具體條款設計上潛在的思考起點。

綜上所述，在認知到個資法之接近權，已構成請求個別研究結果之法律基礎之後，可以再進一步省思，這是不是真能達成妥切結果的法制設計？從上述分析可見，似乎是值得懷疑的。借鏡其他國家的立法，或許適度地開設研究例外，保留更多空間給研究者與研究倫理委員會形塑其提供近用政策，會比僵硬地套用個人資料保護法制下的接近權更好。當然，是否以及如何調整立法，仍視未來之發展。不論是否贊同，研究者在接獲參與者的請求時，仍須以現行個資法的要求為依歸。

肆、政策的願景：提供研究者的思考與建議

超越法律要求之外，研究者如何藉由提供近用政策之塑造，來促成參與者福祉、研究妥善運作與其他公共利益的兼顧和最大化，是接下來進一步努力的目標。如前文第貳章第二節所提及的，相關倫理討論中存在著贊成與反對的尖銳對立，但細觀雙方論點，均僅係建立在某些片面考量的基礎上，因此即使雙方均陳述了部分有說服力的理由，其獲致之單純贊成或反對結論，均不能謂妥適。至於

⁹⁰ Data Protection Act 1998, c. 29, § 33(1).

⁹¹ Regulation (EU) 2016/679, art. 89, 2016 O.J. (L 119) 1, 84-85.

中間立場，雖是本文肯認的方向，但亦如前所呈現的，既有討論意見紛呈，應採取何種揭露標準及如何解釋操作有待爬梳釐清。更重要的是，完整的提供近用政策，並非僅在處理揭露標準的制定，而需要從告知後同意到通知的許多環節之設計來共同構築。這些政策內涵的導引，仰賴對所涉考量因素地毯式地納入理解，而迄今相關討論就此之完整性仍有欠缺。基此，本章以下將首先於第一節完整瀏覽應納入的政策考量，並對當中之爭議問題提出分析，以為後續政策建議之建構鋪路。接著，提出一個由橫向與縱向雙重視角組成之架構，來呈現整合思考前述政策考量後所形塑出的政策建議方向。其中，區分消極揭露與積極揭露的橫向架構將於第二節闡釋，沿著研究流程安排的縱向架構則將於第三節詳述。

一、應納入的政策考量

在架構提供近用的政策之前，首先必須探索相關的政策考量。從著眼的主體為視角，相關考量可以大分為三個層面，一是對參與者的利益或風險，二是對研究者的負擔，三是對社會整體的影響。由此出發並廣泛歸整既有討論，下列考量可能在形塑適切的提供近用政策上發生作用：參與者的接近權、參與者的偏好、隱私/機密性保護、分析有效性、臨床價值、治療誤解風險、參與者對資料的理解與使用能力、對研究者的負擔、對醫療體系的負擔與對研究的公眾信賴。其中前七項考量可歸類於第一個層面，第八項為第二個層面，最後二項則屬第三個層面。以下簡要分述之。

（一）參與者的接近權

如前章所述，我國個資法為實現憲法上之資訊隱私權，已全面性地賦予個人對其個人資料之接近權。當參與者依個資法向研究者要求揭露個別研究結果時，研究者必須尊重其權利之行使。此一因素已不僅是一項倫理考量，而是法律的要求，必須以之作為揭露政策中的前提內容。

(二) 參與者的偏好

除了接近權制度的法律上強制外，尊重個人自主的倫理原則，也要求研究者關切參與者對於取得與其有關資訊的偏好。此一倫理要求，並不僅適用於當參與者積極請求近用時，而是更廣泛地期待研究者將參與者是否取得個別研究結果的決定自主，納入政策考量當中。同時，此一倫理要求關切者，不僅是參與者「知」的期望，也包含「不知」的欲求⁹²。畢竟，知與不知都是自主決定的一環，對二者同等的肯認才能完整體現對個人自主的尊重；而且，強加不欲獲知的資訊，也可能對參與者產生心理上的衝擊等不利益。聯合國教科文組織的「人類基因資料國際宣言」(International Declaration on Human Genetic Data)便提到，研究於進行告知後同意時所提供的資訊，應包含「所涉個人有權決定是否被告知結果」。⁹³明確承認參與者對個別研究結果的知與不知應予保障。而參與者知與不知之偏好存在多樣的可能性，例如有些人對各種個別研究結果均感興趣，有些人則僅希望獲悉特定資訊；而不同的人對於是否取得何種資訊——治療的可獲得性、疾病風險的高低、疾病的嚴重程度、資訊的確定性、疾病具遺傳性與否等面向上不同的資訊——也可能有不同看法。許多研究已嘗試探索一般大眾對於接近個別研究結果的偏好⁹⁴，但是，政策的設定不應該直接採取單一的關於偏好的假設，而應該尊重個別參與者的選擇⁹⁵。即使多數人對於特定資訊有取得或不取得的偏好，也不應據此將該等資訊之提供近用政策設定為對所有參與者提供或不提供，畢竟每個人的選擇都是個人自主的

92 See Bartha Maria Knoppers, *From the Right to Know to the Right Not to Know*, 42 J.L. MED. & ETHICS 6 (2014).

93 UNESCO, INTERNATIONAL DECLARATION ON HUMAN GENETIC DATA, at art. 3 (2003), http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17720&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 該條同時亦指出，此項原則不適用於資料已被不可回復性地連結，或資料並不指向於參與者之個別結果的情形。

94 E.g., Allen et al., *supra* note 11, at 738-46; Murphy et al., *supra* note 9, at 36-43.

95 See Parker, *supra* note 20, at 479.

體現。因此，提供近用政策應將如何納入個別參與者之偏好，即成為其設計上須思考的課題。然而，參與者偏好的多元與可變性的本質，以及難以預知會有何種研究發現的現實，在在為考量個人偏好的政策設計帶來挑戰。同時，參與者的偏好，並不能直接導出提供近用政策的應然，而此一因素如何與其他因素衡量與調和，也是棘手的問題⁹⁶。此外，在參與者為未成年人之情形，在參與研究之初可能由父母之代理同意內容作為本人偏好的替代，但隨著參與者事實上理解與判斷能力的增加，並終將達到完全同意能力的年齡，過程中如何納入參與者本人的偏好，亦須妥善設計⁹⁷。

（三）隱私/機密性保護

在資訊隱私權的價值指引下，研究者應將降低參與者隱私/機密性之風險，作為一項重要的考慮。在降低隱私/機密性風險上，去識別性已廣泛被使用為核心工具，甚至被納入法律當中作為法定要求或解除管制的前提條件⁹⁸。追求隱私/機密性保護——特別是採取去辨識性的作法——和提供個別研究結果存在緊張關係，而成為形塑提供近用政策的一項考量因素。具體言之，為追求隱私/機密性保護而將資料與檢體去辨識性，因為難以回溯個別研究結果所關聯之主體，將對提供個別研究結果的可行性造成障礙；即使是在採取編碼而有回復可辨識性之可能的情況，隱私/機密性保護的原則與考量，也反對回復可辨識性，因而與提供近用追求參與者健康利益的價值相衝突⁹⁹。

96 See Lisa Eckstein et al., *A Framework for Analyzing the Ethics of Disclosing Genetic Research Findings*, 42 J.L. MED. & ETHICS 190, 204 (2014).

97 See Scollon et al., *supra* note 4, at 536.

98 例如個人資料保護法第6條第1項第4款、第9條第1項第4款、第16條第1項第5款、第19條第1項第4款、第20條第1項第5款、人體生物資料庫管理條例第18條第1項及第2項、第8條第2項、人體研究法第19條第1項。

99 William McGeeveran et al., *Deidentification and Reidentification in Returning Individual Findings from Biobank and Secondary Research: Regulatory Challenges and Models for Management*, 13 MINN. J.L. SCI. & TECH. 485, 513-19 (2012).

(四) 分析有效性

所謂分析有效性，或稱為科學有效性，係指檢驗預測臨床結果的正確性¹⁰⁰，也就是檢驗結果是否正確而可靠地識別特定的遺傳特徵¹⁰¹。研究的檢測不同於臨床的檢測，後者必須遵循相關管制法規（例如在美國，執行臨床檢驗之實驗室必須遵循1988年臨床實驗室改進增補法（Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988）之規範並受認證），以確保檢驗結果作為診斷、預防或醫療或評價健康狀況的可信賴性；相對地，前者不受該等管制，以至於其結果不被同等信賴，也本不應提供為臨床用途¹⁰²。以影像研究來說，研究的掃描可能未達臨床等級或被最佳化至臨床診斷的程度¹⁰³。因此，經濟合作暨發展組織（Organization for Economic Cooperation and Development, OECD）所發布的準則便宣示，「來自使用人類生物資料庫與基因研究資料庫之科學研究而未經確證的結果不應回報給參與者，且此應於同意程序中向參與者說明。¹⁰⁴」而分析有效性如何認定，論者見解不一，有認為應藉同儕審查機制來評估，有認為須以新的檢體來重複化驗。而吸引最多關注與爭論的，則為臨床檢驗之管制規範——也就是檢驗結果是否來自受認證合格的臨床實驗室——與分析有效性間的關聯；有認為臨床實驗室認證是分析有效性的核心要素，亦有質疑臨床實驗室認證與分析有效性存在任何必要關聯¹⁰⁵。另有指出，當一項研究包含有提供結果給參與者之規畫時，原則上應提供由符合臨床管制規範之實驗室檢

100 Knoppers & Dam, *supra* note 2, at 579.

101 Eckstein et al., *supra* note 96, at 194.

102 See Maschke, *supra* note 4, at 566; Clayton & McGuire, *supra* note 20, at 474; Wolf, *supra* note 36, at 446-47.

103 Wolf, *supra* note 36, at 446.

104 ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT, GUIDELINES ON HUMAN BIOBANKS AND GENETIC RESEARCH DATABASES 11 (2009), <https://www.oecd.org/sti/biotech/44054609.pdf>.

105 Eckstein et al., *supra* note 96, at 194.

驗之結果，或將該結果經該等實驗室確認。然而，研究脈絡中產製的資訊，有可能不易由符合臨床管制規範之實驗室確認，即使能夠確認，既有的檢體也可能不是經由符合臨床管制規範之實驗室的檢體追蹤程序所取得與儲存，以至於必須重新取得檢體以擔保檢體未被污染。有鑑於這些研究脈絡下的實際困難，另一種可能作法是提供不符合臨床檢驗管制規範的結果，同時警示參與者不應基於這些結果採取任何臨床行動，並提供如何進一步取得臨床協助的有關資訊¹⁰⁶。綜合上述觀察，某種程度的分析有效性，應該是提供個別研究結果的前提，似已屬共識。至於以符合臨床檢驗管制規範為要件，則存在爭議。所謂以符合臨床檢驗管制規範為要件，理論上有二種不同設計的可能：一是不符此要件之個別研究結果即不提供，二是研究者必須將不符此要件之結果送交臨床實驗室確認或重驗後提供。由於前者將大幅排除提供個別研究結果的可能性，後者則存在可行性疑義，也對研究者造成不合理的負擔，因此本文認為，將臨床檢驗管制規範與分析有效性等同之見解，不論如何設計，恐均非政策上可欲的選項。在此前提下，提供近用政策是否及如何納入提升分析有效性的機制，以及是否及如何提供減少參與者誤解或誤用資訊的警示與協助，便是分析有效性此一考量因素遺留的課題。

（五）臨床價值

提供個別研究結果議題的出現，主要起因於這些結果可能提供參與者健康上的益處。於是，從研究產生出來的資料對於參與者之健康維護或促進究竟產生多少意義，便成為是否提供近用的一項重要考量。此一考量因素已被用不同的概念語彙來開展論述，包括臨床有效性（clinical validity）、臨床重要性（clinical significance）、臨床相關性（clinical relevance）等，雖然不同論者對所使用概念之界定並不完全相同，因而造成討論上的紛雜，但所欲關切的重點相

¹⁰⁶ Jarvik et al., *supra* note 31, at 823.

同地落在對參與者的健康益處此一因素上¹⁰⁷。進一步解析，幾項因素左右著吾人對於臨床價值的理解。

第一，臨床有效性或相類概念，也就是察知或預測症狀或疾病等結果的一致性與準確性¹⁰⁸。科學對於特定基因與疾病間關聯性的了解，須經過一條從懵懂到確信的道路。當在科學上已經確立，BRCA2基因的特定突變可預期將伴隨生涯49%乳癌風險及18%卵巢癌風險時，檢測出參與者帶有該特定突變，對於其乳癌與卵巢癌的預測便具有臨床有效性。相對地，當某些基因突變與疾病風險間的關係仍在摸索階段時，即便檢測出該基因突變，亦無法明確連結疾病的預測，而此種欠缺臨床有效性的個別研究結果，恐難提供參與者實質的益處，甚且反有帶來心理負擔的害處。然而，科學上的認識，從僅獲得解釋性或研究性的資料（exploratory or research data），到相當可能的有效（probable valid），到已知的有效（known valid），具有演化變遷的本質，而何等條件構成有效？何時可認為從相當可能轉變為已知的有效？需求如何的廣泛共識？在在存在爭論¹⁰⁹。同時，光譜中不同程度的有效性如何在提供近用政策中被考慮？亦有待思辨。

第二，健康影響的嚴重性：有以臨床重要性（clinical importance）稱之，意即個別研究結果發現之狀況對參與者健康影

107 See Knoppers & Dam, *supra* note 2, at 579; Eckstein et al., *supra* note 96, at 195-96.

108 Lévesque et al., *supra* note 19, at 589.

109 Gaile Renegar et al., *Returning Genetic Research Results to Individuals: Points-to-Consider*, 20 *BIOETHICS* 24, 32 (2006). 所謂已知的有效與相當可能的有效，若參酌美國食藥署的指引對生物標記（biomarker）的分類，前者須「醫學或科學社群對於該結果之生理、毒理、藥理或臨床重要性有廣泛的共識」，後者則須「存在科學架構或諸多證據似乎顯現出該結果之生理、毒理、藥理或臨床重要性」，但基於一些因素未達已知的有效程度，例如相關資料尚未能提供予公共的科學驗證、相關資料尚未獲致決定性的結論、或該結果尚未經獨立的檢證等。FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, GUIDANCE FOR INDUSTRY: PHARMACOLOGIC DATA SUBMISSIONS 18-19 (Mar. 2005), <https://www.fda.gov/downloads/drugs/guidancecomplianceregulatoryinformation/guidances/ucm079849.pdf>.

響的程度¹¹⁰。另亦有以健康重要性（health importance）稱之，且值得注意的是，其強調對生育上的重要性亦被包含在內，因基因資訊可能有助於參與者採取行動，避免對其後代的嚴重結果¹¹¹。理論上愈是嚴重的疾病，參與者愈有因應的需求，因此個別研究結果所連結到的健康影響程度，成為評判對參與者價值的重要指標。影響所及，許多倫理指引已將此一因素納入其應或得提供的標準當中。然而，嚴重或輕微牽涉主觀的判斷，如何提供較為明確的判斷標準？同時，嚴重或輕微亦非截然二分，光譜中不同程度的嚴重性如何在提供近用政策中被考慮？均形成挑戰。另外，若生育重要性也被納入此處臨床重要性或健康重要性的概念當中，則具生育重要性之結果應落入應獲得提供的類屬，相較起來爭議更大¹¹²。

第三，可行動性（actionability）：所謂可行動性，廣義的理解係指獲悉個別研究結果可導出某種行動的潛力。狹義的理解則聚焦於臨床上的可行動性，有以是否存在有效的治療或預防之選項來界定，亦有較廣泛地以是否具有改善健康結果之潛力來界定者¹¹³。臨床可行動性概念的提出，係考量某些疾病或健康風險，倘若欠缺治療、預防或改善之可能，對參與者並無實質幫助，反可能帶來心理負擔。因此，許多倫理指引在設定其應或得提供之規則時，便將臨床可行動性作為判別標準之一。然而，可行動性具有變遷性與脈絡性，一方面治療或預防的方法會隨著醫學的進展而出現或改變，二方面治療或預防方法得否獲得，也視參與者所處的政治經濟環境與條件而定。以發現BRCA1或BRCA2基因突變之資訊為例，對於高收入背景的女性而言，有許多協助其管理癌症風險的選項，但對於

110 Alberto (Betto) Ortiz-Osorno et al., *Considering Actionability at the Participant's Research Setting Level for Anticipatable Incidental Findings from Clinical Research*, 43 J.L. MED. & ETHICS 619, 619 (2015).

111 Wolf et al., *supra* note 5, at 231.

112 Wolf et al., *supra* note 38, at 373.

113 See Eckstein et al., *supra* note 96, at 197.

某些國家或階層的女性而言，其可獲得的選項可能極其有限甚或不¹¹⁴。而是否可取得治療或預防之資源，也可能隨時間遞嬗，例如在研究進行之初參與者欠缺該等資源，但在研究結束之前卻可獲得政府應對相關疾病的社會福利輔助¹¹⁵。這些變因大大增加了評估可行動性的挑戰，也產生在研究進行中對於可行動性再評估的課題。另一方面，欠缺臨床可行動性的資訊，對參與者仍可能具有價值，包括間接的臨床價值與直接的非臨床價值等。所謂間接的臨床價值，係指雖無法連結直接增益參與者的臨床行動，但提供參與者臨床知識之價值，包括增加對疾病的理解、減少未來診斷的漫長過程、協助生育之決策等；所謂直接的非臨床價值，係指提供參與者與臨床無關的直接助益，例如購買人壽或醫療保險、通知家人等¹¹⁶。從另一個角度來看，也就是將可行動性的行動擴大理解，而不僅限於臨床行動。一項調查研究倫理委員會主席之意見的研究顯示，對於一項預期80歲將有40%黑色素瘤風險與60%胰臟癌風險，但臨床可行動性未確立的基因突變資訊，68%的受訪者仍認為很可能或確實應該提供給參與者¹¹⁷。顯見臨床可行動性的未備，恐怕不宜直接導出提供近用的否定結論。那麼，何等行動或何等價值可被轉化為提供近用政策中的準據？仍有待深思。

（六）治療誤解風險

研究之目的，在發展或貢獻於可一般化的知識；相對地，醫療則主要係為了病患的利益而存立。而治療誤解之特徵，即在此二者的混淆，也就是個人錯誤地認為研究——至少是部分地——具有使個別參與者受益的目的，而提供個別研究結果已引發這樣的爭

¹¹⁴ Ortiz-Osorno et al., *supra* note 110, at 620.

¹¹⁵ *Id.* at 621.

¹¹⁶ Eckstein et al., *supra* note 96, at 202.

¹¹⁷ Fernandez et al., *supra* note 4, at 516.

議¹¹⁸。論者指出，支持提供個別研究結果，可能會因為強化了參與者可獲得個人利益的想法，而助長了治療誤解¹¹⁹。而治療誤解可能導致參與者在選擇是否加入研究時，作成並非真正符合其偏好與價值的決定；也就是說，未能完全理解其所參與係以研究為目的的本質，將損害其告知後同意的有效性¹²⁰。雖然治療誤解升起倫理疑慮，但是，提供個別研究結果是否必然造成治療誤解？在許多研究脈絡中，參與者都可能獲得個人化的利益，例如接受新藥試驗而改善疾患、取得金錢或物品作為參與研究之補償等。在追求可一般化知識的前提下讓參與者獲益，從來都不是被拒斥的。因此，提供個別研究結果雖然讓參與者獲益，但這本身並不成為問題。成為問題的，是在招募參與者的程序中，告知存在提供個別研究結果的可能性時，參與者是否會因為過度放大取得資訊的機率與價值，以至於作成受到干擾的、非真正自主的同意。因此，如何在提供近用政策中，特別是有關告知後同意的環節，確保參與者確實認知目的之研究屬性、其獲益的真實可能、其所獲照護之標準與醫療脈絡間的差異等，便成為重要——而也困難——的課題。

（七）參與者對資料的理解與使用能力

研究中產製出的個別研究結果往往具有複雜、專業、發展中與不確定的本質，帶來參與者理解上的困難，參與者可能錯誤解讀、連結不適當的後續處置，或失落在如何採取臨床應對當中¹²¹。而純粹的科學研究者通常不具有遺傳諮詢或醫療照護的專業，研究計畫中通常也無資金或機制提供該等服務，這使得向參與者提供審慎的溝通成為極大的問題¹²²。理論上，結果宜以有效且讓參與者能夠理

118 Forsberg et al., *supra* note 20, at 1546.

119 Clayton & McGuire, *supra* note 20, at 474.

120 Gail E. Henderson et al., *Clinical Trials and Medical Care: Defining the Therapeutic Misconception*, 4(11) PLOS MED. 1735, 1738 (2007).

121 Clayton & McGuire, *supra* note 20, at 476.

122 Cassa et al., *supra* note 27, at 425.

解的方式來傳達，並維持住研究與醫療的分際；而適切的方法須視具體的研究脈絡而定¹²³。使用電話、信件或電子郵件的方式，優點是快速方便，或許適用於某些研究類型，但若涉及的是較高科學專業的研究，參與者理解與使用資訊的可能性即頗有疑問。以基因研究為例，有認為負責與參與者進行溝通者，應具備下列條件：一、了解研究所涉之科學以及產製結果的實驗室的性質（例如臨床或研究實驗室）；二、理解對個人及其家庭的潛在社會與心理衝擊；三、能以適當的語言和文化敏感度進行有效溝通與回答疑問；四、知道何時與如何引介參與者進一步的照護與資訊¹²⁴。更具體來說，有建議基因研究的結果應透過遺傳諮詢師或其他符合資格的臨床專業人員來傳達；亦有基於遺傳相關專業人員的缺乏，建議透過醫療照護專業人員或電腦輔助之方式來傳達¹²⁵。亦有指出四種潛在的安排選項，包括：一、提供參與者資源表列，以利其自行採取後續行動；二、轉介紹相關醫療專業人員；三、為參與者向相關醫療專業人員約診；四、以研究經費支付或透過研究計畫提供醫療照護¹²⁶。綜而觀之，提供近用政策應考量研究與參與者的性質，思索適切的傳達資訊方法。在具有較高科學專業性的研究脈絡，採取強化參與者理解的措施有必要受到考慮。然而，在各種潛在安排選項中做抉擇時，又牽涉研究團隊中人員的專業性、研究計畫的經費資源、參與者的偏好與機密性保護，以及在幫助參與者理解上的實效性等思考。

（八）對研究者的負擔

提供個別研究結果所引發的最大疑慮，即在其加諸研究的可觀負擔上。基於研究資源的有限性，研究資源應主要投入在科學的發

123 Jarvik et al., *supra* note 31, at 823.

124 Renegar et al., *supra* note 109, at 34.

125 Jarvik et al., *supra* note 31, at 823.

126 Prince et al., *supra* note 23, at 831.

現上¹²⁷。而提供個別研究結果政策所伴隨而來的，並非可忽略的成本。首先，即便許多研究能獲得全基因體的基因變異，這些研究之設計通常均未要求對這些資料進行評估，因此研究者若要查知有意義之基因變異是否存在，需要刻意地對個別基因進行檢視。其次，即便個別基因變異的資料被產生出來也受到評估，確認該等變異是否確實會引發疾病，通常需求包括分析主要文獻在內的廣泛審視。論者曾以某一研究為例說明，每一變異之審視可能平均需要20分鐘的投入，有些變異甚至需要數小時的審視與討論，而大部分的變異其實並不引發疾病¹²⁸。同時，隨著人類發現愈來愈多與疾病相關的基因變異，整體成本將逐步增高。一項2011年的研究指出，如果依循美國國家心、肺與血液研究院工作小組提出之建議所採的標準，基因體中保守估計有7,171項變異應分享給參與者，若採較寬的解釋則約有高達11,082項變異應提供，且以過去四年的發展為基礎，預估到2015年，此一數字將從11,000上升到超過16,000。審視如此大量且不斷成長中的知識並適用到對每一個參與者的評估中，將對研究者造成極大的負擔，甚至可能是不切實際的期待¹²⁹。況且，研究者可能並不具有找到可提供之結果的能力與資格。例如，一個進行核磁共振造影研究的研究人員，並不被期待具有神經放射師之專業以審視核磁共振掃描結果¹³⁰。第三，與參與者聯繫以提供個別研究結果，亦須成本。第四，若欲採行更加負責任的實踐，包括將結果送交符合臨床檢驗管制規範之實驗室進行確證，以及透過適格的專業人員說明所提供資訊，更須額外成本的投入¹³¹。

若是在生物資料庫的研究脈絡，提供個別研究成果的安排更加複雜。複雜性來自於，生物資料庫研究係由多個角色所組成，而基

127 Jarvik et al., *supra* note 31, at 820. See also Wolf et al., *supra* note 5, at 236.

128 Jarvik et al., *supra* note 31, at 820.

129 Cassa et al., *supra* note 27, at 423-24.

130 Wolf et al., *supra* note 5, at 236.

131 Jarvik et al., *supra* note 31, at 820.

於機密性保護的考量，資訊的流通往往是在去識別性的狀態下。詳言之，生物資料庫所從事者，係蒐集、儲存檢體與資料，並以去識別性之型態釋出給研究者，讓研究者進行研究¹³²。因此，是否存在具潛在提供價值之研究結果，生物資料庫無法掌握，而可能產製該等研究成果的研究者，則無從知悉參與者的身分以踐行資料提供。在此情境，當研究者發現具潛在提供價值之研究結果時，需回報給生物資料庫，由生物資料庫回復參與者之可識別性，並進行通知¹³³。另外，實務上亦有合作型之生物資料庫，負責制定實施的政策和方法，整合許多蒐集與儲存檢體和資料的參與點或機構¹³⁴。在此情境，個別研究結果的流動，便包含從研究者到生物資料庫行政中樞，生物資料庫行政中樞到個別參與點或機構，由個別參與點或機構回復可識別性之後，再到參與者手上¹³⁵。確保各個角色各盡其職、各項環節順暢運作，恐牽涉生物資料庫結構的改造，自然也升起成本議題。而且，既有的生物資料庫行政部門，也和個別研究者一樣，恐怕欠缺審視與評估特定基因變異是否應提供參與者的能力¹³⁶。建立一個監督單位，例如結果提供監督委員會，固有益處，但也會提高生物資料庫的營運支出¹³⁷。

132 人體生物資料庫管理條例第18條第1項規定，「設置者就其所有之生物檢體及相關資料、資訊為儲存、運用、揭露時，應以編碼、加密、去連結或其他無法辨識參與者身分之方式為之。」故取得檢體與資料的研究者並無法取得可識別性的資料。

133 See McGevean et al., *supra* note 99, at 533-34.

134 Michael Ferriere & Brian Van Ness, *Return of Individual Research Results and Incidental Findings in the Clinical Trials Cooperative Group Setting*, 14 GENETICS MED. 411, 411-12 (2012).

135 See McGevean et al., *supra* note 99, at 531-32.

136 See Gloria M. Petersen & Brian Van Ness, *Returning a Research Participant's Genomic Results to Relatives: Perspectives from Managers of Two Distinct Research Biobanks*, 43 J.L. MED. & ETHICS 523, 526-27 (2015).

137 Ferriere & Ness, *supra* note 134, at 414.

在某些特殊情形，提供個別研究結果將損害研究，甚至導致研究成為不可行。*Ande v. Rock*案¹³⁸之背景事實，例證了此一情形。研究團隊利用新生兒篩檢剩餘血液樣本進行囊狀纖維化（cystic fibrosis）之研究，其實驗假設為，在症狀顯現前給予帶有囊狀纖維化之新生兒特定的營養療法，將緩和其疾病的發展與對健康影響的嚴重程度¹³⁹。為驗證此一假設，有一半的參與者父母被告知陽性檢驗結果並提供營養方案，另一半則為對照組，不會得到通知。在被置於對照組中之原告提起的訴訟中，法院認為原告未能指出存在明確建立的任何財產或人格利益，因研究者未告知檢驗結果而受到侵害¹⁴⁰。倘若相反地，法院肯定研究者有提供檢驗結果的義務，則對照組將自然消失，也使研究的有效性無法建立。

此外，提供個別研究結果的政策選擇可能為研究者帶來法律風險。在參與者未請求近用的情形，理論上研究者並無提供個別研究結果的法律上義務。但是，倘若在研究者的提供近用政策或說明同意書中，載有主動提供的條款，即可能形成契約義務，而成為參與者提起訴訟的依據¹⁴¹。這意味著，研究者最大化參與者福祉的善意，可能為其帶來額外的司法程序負擔；即使在個別案件中，訴訟的結果釐清了研究者之未提供符合其提供近用政策/說明同意書所設定的條件，但只要存在主動提供的條款，就有訴訟程序被啟動的可能¹⁴²。

138 2002 WI App 136.

139 *Id.* at ¶ 2.

140 *Id.* at ¶ 22.

141 關於研究中告知後同意在契約法上的意涵，可參照洪敏瑜，醫學研究中告知後同意之法律意涵，國立清華大學科技法律研究所碩士論文，頁56-72（2009）。

142 See Scholtes, *supra* note 47, at 1181 (stating that “[a]s researchers adopt these ethical recommendations, these new practices may give rise to a corresponding legal standard of care for researchers.”).

(九) 對醫療體系的負擔

在臨床的脈絡，已有許多討論關注到針對消費者的基因檢驗對於醫療照護體系所增加的成本，因而極度不鼓勵那些會引致後續不必要檢驗及其他副作用的基因檢驗。而在提供個別研究結果的脈絡，也應有同樣的顧慮。特別是那些不屬常規醫療的檢驗結果，參與者可能因而開啟一段在醫療體系中衝撞探索之旅，除了可能為參與者本身帶來焦慮與支出外，對醫療體系也將加諸更大的負擔，從醫療資源有限性的觀點來看，存在對公共利益的損害¹⁴³。

(十) 對研究的公眾信賴

基於一般大眾對取得個別研究結果高比例的期待¹⁴⁴，研究者在提供近用政策上採取積極而負責任地為參與者福祉考量的態度，將有助於公眾對研究的合作參與以及對研究的一般性信賴，而這將帶來許多潛在的社會價值，包括增加對研究之公眾支持、促進更多科學發現、增進關聯人類與環境健康的積極主義、增加科學進展轉化為政策的可能性等，而這些對公共健康將產生正面效應¹⁴⁵。已有大規模研究計畫明白以向參與者高度開放個別研究結果為其核心價值，作為建立與參與者間之夥伴關係、贏取公眾信賴與合作參與之途徑¹⁴⁶，為此一政策考量作了絕佳的例證。

在瀏覽所涉之諸多政策考量因素後，以下二節將藉由一個由橫向與縱向雙重視角組成之架構，對這些思考進行整合，以呈現本文對在提供近用政策之建構上的建議。

¹⁴³ Clayton & McGuire, *supra* note 20, at 475.

¹⁴⁴ 參照前註9至13之附隨本文。

¹⁴⁵ NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE, *supra* note 1, at 80.

¹⁴⁶ See NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, ALL OF US RESEARCH PROGRAM PROTOCOL 5-7, 49-59 (v1.7, 2018), https://allofus.nih.gov/sites/default/files/aou_operational_protocol_v1.7_mar_2018.pdf.

二、橫向架構的確立：消極揭露與積極揭露的區分

前文政策考量（一）便揭示了，個資法所賦予之接近權構成提供近用政策形塑中的一項關鍵要素。由其出發，消極揭露與積極揭露區分的構造浮現。簡言之，在消極揭露，也就是參與者請求近用下的情形，研究者有依個資法規定提供個別研究結果的義務；相對地，在積極揭露，也就是未經請求之情境，研究者、研究倫理委員會與研究機構/生物資料庫宜衡量相關利益，納入各項政策考量，架構提供近用的整體規劃。

詳言之，在消極揭露面向，提供近用政策應將個資法之規範納入，以形成運作內涵。具體來說，政策中有關告知後同意的環節，應遵循個資法第8條第1項第5款之規定，將第3條之內容納入告知事項中，讓參與者知悉其得依個資法規定行使「一、查詢或請求閱覽。二、請求製給複製本。三、請求補充或更正。四、請求停止蒐集、處理或利用。五、請求刪除。」等權利。政策中並應建構參與者請求的管道與程序，落實個資法第10、13條等規定。另外，個資法第14條允許收取必要成本費用，有助於衡平參與者之接近權與研究者之成本負擔，而所謂必要成本費用的計算與收取方式，也宜在政策中敘明。較為複雜的是在生物資料庫的研究脈絡下，當參與者向採樣的生物資料庫請求近用資料時，進行次級使用的研究者所取得的個別研究結果，並不在生物資料庫的掌握中。此時，生物資料庫是否有義務找出該參與者之檢體與資料曾釋出的對象，並藉由釋出編碼向接受釋出的研究者索取個別研究結果，再提供給參與者？由於生物資料庫與次級使用之研究者為不同主體，參與者得依法向生物資料庫請求的範圍，應僅限於生物資料庫所掌有之個人資料；倘若匿名釋出後所衍生的資料也在提供義務範圍內，將無限延伸而欠缺合理界限，而造成對研究的不當負擔（關聯前揭政策考量（八）），對隱私/機密性維護也產生難以預期的風險（關聯前揭政策考量（三））。

相對於消極揭露，積極揭露的面向尚無法律規範。換句話說，尚不存在加諸研究者主動提供之法律上義務之規範。而從前節就相關因素所為分析可知，主動提供近用所牽涉的高度複雜性與爭議性，以及不同研究脈絡的歧異背景，使得應如何塑造政策內容，並無絕對答案。研究倫理委員會、生物資料庫倫理治理機制或主管機關等監督者，應容留研究者一定的迴旋空間。而研究者與研究機構/生物資料庫，則應秉持善意，針對個別研究之特質，思考提供近用的可能性。由於積極揭露政策的多樣化可能，本文將於下節進一步分析討論，呈現不同的潛在發展。

三、縱向架構的形塑：研究流程的視角

除了橫向的架構區分外，另一個切入提供近用政策架構的視角，是縱向地循研究開展的流程，分就告知後同意、確認與個案決定、通知等階段，思考可能的安排。本節以下即將分別就此三個階段，探索潛在的作法方案。而如前節提及的，本節主要之功能在為超越法律義務之外的積極揭露面向，鋪排提供近用政策值得考慮採取的形貌，以期待理想的個別研究結果提供之實現。但當然，當中所建議之安排與機制，在參與者提出請求的消極揭露面向，也同樣可以發揮作用。同時值得附帶澄清的是，由於承認積極揭露所涉之複雜性、爭議性與脈絡性，下文的分析討論，並無意表達各種不同脈絡之研究均應或宜提供近用之意，合先敘明。

（一）告知後同意

如前於**政策考量（二）**所述，尊重參與者在資訊取得上的偏好，是一項重要的目標，這也是許多倫理指引中，均將參與者同意作為提供近用的標準之一的原因。而踐行告知後同意程序的階段，正是探詢參與者意向或取得參與者同意的適當場合。然而，即便研究者秉持善意，承擔成本，願意尊重參與者的偏好，探詢參與者意向或取得參與者同意一事，並不如想像中單純。如前曾提及的，參

與者偏好的多元與可變性的本質，以及難以預知會有何種研究發現的現實，為如何「告知」以取得「同意」增添挑戰。

提供近用政策或許有下述幾種設計的可能。第一，預先設定明確特定的標準，將這些標準清楚告知參與者，以取得其同意。例如，如同許多倫理指引一般，以具有分析有效性、臨床有效性暨重要性、臨床可行性等為指標，界分揭露、可能揭露、不揭露之情狀，並嘗試更明確地說明在這些指標的意涵、所採認定標準及其處理程序¹⁴⁷。又如，更加明確地侷限於特定具健康重大影響之疾病或基因發現，作為取得同意的標的。第二，向參與者說明再聯繫的可能，由其選擇是否接受再聯繫；於事後評估有價值的個別研究結果存在時，再由已同意再聯繫之參與者決定是否接受該等結果資訊¹⁴⁸。第三，發展創新的機制，讓參與者有機會在獲取動態資訊的情況下提供其動態的偏好¹⁴⁹。此種設計也就是「動態同意」(dynamic consent)方法的應用。所謂動態同意，係個人化、線上的同意與溝通機制，以促成研究者與參與者間雙向且持續性的溝通。例如在生物資料庫之脈絡，參與者得於起始給予概括同意，其後透過線上平台，在原本同意中未預見之新活動（例如研究結果之提供）出現時，給予新的同意，或因應情況的變遷而改變先前的同意選擇¹⁵⁰。此一動態同意策略，已被認為是因應個別研究結果之提供的適切方法¹⁵¹。

對某些範圍狹窄、目標特定的研究來說，潛在的個別研究結果

147 See Wolf et al., *supra* note 5, at 233.

148 See Ortiz-Osorno et al., *supra* note 110, at 630.

149 See Knoppers, *supra* note 92, at 9.

150 Isabelle Budin-Ljøsne et al., *Dynamic Consent: A Potential Solution to Some of the Challenges of Modern Biomedical Research*, 18(4) BMC MED. ETHICS 1, 3 (2017).

151 Kristin Solum Steinsbekk et al., *Broad Consent versus Dynamic Consent in Biobank Research: Is Passive Participation an Ethical Problem?*, 21 EUR. J. HUM. GENETICS 897, 901 (2013).

的樣貌有可能較容易預測，此時第一種設計有發揮餘地。相對地，對於範疇廣泛、目標開放，而潛在的個別研究結果不易事前預知的研究，就有偏向仰賴第二種設計的需求。值得進一步理解的是，此二設計選項概念具有流動關係，特別是，在第二種設計下向參與者說明再聯繫的可能時，不太可能對於何時啟動再聯繫完全不加著墨，而對於何時啟動再聯繫——例如何時構成應或宜提供參與者個別研究結果之情境——的描述愈是清楚詳細，也就愈偏向第一種設計；而在第一種設計下即使給予參與者有關提供近用標準清楚詳細的說明，倘若在提供個別研究結果時，仍欲再次確認參與者的意願，則實際上也是混和運用了第二種設計¹⁵²。至於第三種設計，理論上適於不同的研究態樣，可因應個人偏好的多元與可變性，甚至也可能是處理未成年參與者變動中同意能力的妥適工具。不過，採此設計須面對較高的成本，以及建置線上互動系統所伴隨而來的額外隱私風險等議題（關聯前揭政策考量（三）、（八）），仍須考量參與者之性質、研究規模與資源、機構之執行能力等因素。

除探詢參與者偏好外，在告知後同意程序還有一項重要的任務值得重視，即在釐清研究與醫療的分際上提供適切的說明。如前於政策考量（六）曾提及的，治療誤解是提供個別研究結果政策遭致反對的一項重要因素。但也如同前文所指出的，產生治療誤解的可能性，不應成為完全拒卻提供個別研究結果的理由，而應將努力投入於透過妥適的告知後同意程序，消弭治療誤解的風險。因此在告知事項中，宜依照個別研究之性質，納入充分之說明，確保參與者確實認知目的之研究屬性、其獲益的真實可能、其所獲照護之標準與醫療脈絡間的差異等。舉例來說，作為研究基礎設施，以釋出供次級使用而非本身進行研究為目的之生物資料庫，若採取不要求次

152 有認為，除於邀請參與者加入研究的階段取得參與者是否欲獲得個別研究結果之意向外，於提供結果之階段亦應再次確認參與者之決定，因為在研究進行期間參與者可能改變心意。Renegar et al., *supra* note 109, at 35.

級使用研究者回饋個別研究結果之政策，而僅於本身產製或獲悉符合提供標準之資訊時提供參與者，則實際上參與者獲得個別研究結果的機率甚低；於此情形，生物資料庫在告知提供近用政策時，應妥善解釋相關機制，使參與者正確理解獲得個別研究結果的可能性。此外，若提供近用政策在確認程序上，採取不經臨床實驗室複驗即提供之作法，亦有需要說明向參與者所提供資訊與醫療檢驗結果之差異。

（二）確認與個案決定

當可能符合提供近用標準之事件出現時，研究者應採取特定程序以獲致是否提供個別研究結果之決定。此一程序的背後，是為了確保前揭政策考量（四）、（五）論及之分析有效性與臨床價值（包括臨床有效性、健康影響的嚴重性、臨床可行性）合於設定之要求，以回應相關的政策考量。

首先，在分析有效性方面，在應否將分析有效性等同於臨床檢驗管制規範之問題上的立場，將影響提供近用的可能性，也影響是否應將送交臨床實驗室檢驗納入必經程序中之決策。如前所述，本文在此議題上採取否定立場，即認為個別研究結果未達臨床檢驗之標準，不應成為必然阻絕參與者近用的因子；但是，即便研究者決定不以經臨床檢驗為提供近用前提，其仍須採取一定的確認程序，來擔保某程度的分析有效性。這包括——但不限於——再次確認：第一，該分析結果是否確為該特定參與者所有；第二，該分析結果是否在適當操作下產生；第三，是否需要再次檢驗¹⁵³。而此一確認應獨立於產出該結果之實驗室的程序，以擔保提供結果之可信賴性¹⁵⁴。同時，在可行的情況下，研究者宜嘗試使用符合臨床要求的

¹⁵³ Wolf et al., *supra* note 5, at 231.

¹⁵⁴ See NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE, *supra* note 1, at 124.

程序與設施¹⁵⁵。在歐洲與美國，已有一些倡議致力於建立標準化的研究管理系統¹⁵⁶，若這些研究管理系統被建立起來，亦可成為達成分析有效性之遵循標準的選項。其次，在臨床價值方面，在研究者不具備足夠的專業知識之情形，有需要與相關專家合作，來完成所需的判斷¹⁵⁷。而與相關專家合作或專業資源的取得，宜在研究計畫中便預做安排。

由於個案中分析有效性與臨床價值的判斷，對研究者可能存在相當的挑戰性，而需求制度性機制的協助。例如在大型計畫或大型生物資料庫之情境，或可設置負責此任務之委員會，邀集所涉領域之專家，從事提供近用之個案判斷¹⁵⁸。而在欠缺此等機制之情形，負責研究計畫之審查與監督的研究倫理委員會，可扮演協助的角色。詳言之，當研究者對於應否將特定個別研究結果提供參與者有疑問時，得送請研究倫理委員會檢視，倘若研究倫理委員會認為本身亦欠缺判斷能力，得透過內部程序送請有關專家協助，以給予研究者是否提供近用之建議。

在國家乃至國際的層級，若能啟動持續性的研究審視努力，製作值得提供參與者的基因結果清單，將對研究者產生很大的助益。美國國家心、肺與血液研究院工作小組便建議，為達成一致性與嚴謹性，應建立一國家中央層級的諮詢委員會，審視與遺傳性風險因

155 See PRECISION MEDICINE INITIATIVE (PMI) WORKING GROUP, THE PRECISION MEDICINE INITIATIVE COHORT PROGRAM – BUILDING A RESEARCH FOUNDATION FOR 21ST CENTURY MEDICINE 43-44, 67 (2015), <https://www.nih.gov/sites/default/files/research-training/initiatives/pmi/pmi-working-group-report-20150917-2.pdf>.

156 NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE, *supra* note 1, at 107-15.

157 Wolf et al., *supra* note 5, at 231.

158 Wolf et al., *supra* note 38, at 375; Ferriere & Ness, *supra* note 134, at 414; Maschke, *supra* note 4, at 569-71; PRECISION MEDICINE INITIATIVE (PMI) WORKING GROUP, *supra* note 155, at 43-44, 67. 另亦有建議由研究倫理委員會建立負責此一任務的次級委員會。Stephanie A. Alessi, *The Return of Results in Genetic Testing: Who Owes What to Whom, When, and Why?*, 64 HASTINGS L.J. 1697, 1724-25 (2013).

子有關之證據，提供指引以利研究者、研究機構與研究倫理委員會參酌決定，何時一項基因結果應或得向參與者傳達；而此一諮詢委員會應納入各類利害關係人，採取思辨的程序，並定期重新檢討其結論¹⁵⁹。在支持此一基因研究結果清單之建議的同時，也須注意到其限制，尤其是未能處理非基因性質之發現的問題；因此，若建立一國家層級委員會，該委員會亦應扮演非基因性質個別研究結果之政策與共識意見的交換平台¹⁶⁰。

（三）通知

在決定將個別研究結果提供近用後，接下來須處理如何通知參與者之議題。理論上，通知的方法包括面對面、透過信函、電子郵件或電話、透過線上系統，或上述方法的組合，例如以電子郵件通知參與者得進入線上系統取得相關資訊¹⁶¹。而除了這些技術層面的選擇外，通知方法之決策上更重要的議題，是如何透過通知者、通知內容與其他配套措施的安排，以避免參與者因理解上的困難而遭致後續勞力、時間與費用的無端消耗乃至不必要的心理衝擊（前揭政策考量（七））。潛在的配套作法選項包括：一、在研究規劃中便安排由具足夠專業能力者作為個別研究結果的通知者，例如在基因研究中，由遺傳諮詢師或其他遺傳學專業人員提供結果。二、轉介給相關醫療專業人員、為參與者向相關醫療專業人員約診，或將結果交給參與者預先提供的家庭醫師人選。三、提供參與者資源表列，以利其自行採取後續行動，例如在基因研究中，於傳達個別研究結果時一併提供醫學遺傳學專科醫師、遺傳諮詢師或醫療院所遺傳諮詢門診表列資料。第一種選項在研究團隊裡包含適切的專業人員時為簡易可行的方案，但若不具備此等條件，便需要額外研究資

159 Fabsitz et al., *supra* note 29, at 577.

160 Wolf et al., *supra* note 38, at 374.

161 Parker, *supra* note 20, at 454.

源的支持；第二種選項則牽涉參與者是否同意其資料被移轉給第三人的問題，須在參與研究的階段，處理好相關事項的告知後同意；第三種選項在向參與者通知個別研究結果時由於欠缺直接的專業諮詢或安排，應充分告知該結果與醫療檢驗結果的差異，並強烈建議參與者向專業人員尋求諮商。

另外，在生物資料庫研究之脈絡，存在研究者、生物資料庫乃至蒐集點或機構等多個角色的涉入，已如前於**政策考量（八）**之討論所述，因此產生由誰執行通知之議題。次級使用的研究者因為欠缺參與者之可識別性資料，基本上無法成為執行通知的主體。相對地，生物資料庫則應扮演核心角色。在生物資料庫本身負責資料與檢體之蒐集與儲存之情形，由其擔負通知結果的任務，應屬必然。但在合作型的生物資料庫之情形，考量個別參與點或機構才是掌握資料與檢體，並在採集檢體與更新資料時與參與者進行互動的主體，由個別參與點或機構——而非生物資料庫行政中樞——執行結果通知，可能是妥適的安排；至於生物資料庫行政中樞，則負責在通知方法上進行統合，促成適切與一致化的通知實踐。當然，也不排除由生物資料庫行政中樞建立單一的管道來進行通知，例如採行線上系統的方式，允許參與者隨時透過個人帳號密碼進入參與者入口網站，取得與其有關之資料。

前述三個階段的政策環環相扣。例如，確認與個案決定所採程序及標準，以及通知個別研究結果之方式，可能成為告知後同意階段說明內容的一部分。又如，建立線上系統機制，可能整合在告知後同意階段的「動態同意」方案與在通知階段的「線上系統」提供近用方法，讓參與者可以隨時表達或變更其偏好，並隨時取得產生的個別研究結果；而由於線上系統屬於無專業人員向參與者提供諮商情形，應配套「提供參與者資源表列」之方案，並充分說明結果的研究屬性與向專業人員諮商的重要性。

伍、結論

個別研究結果向參與者提供近用的議題，已在國際間引起廣泛關注。雖然相關倫理論述與主張紛呈，研究計畫與生物資料庫的具體實踐亦各異，但思索是否在特定情形應或得提供近用，已成為新時代之研究者不得不面對的挑戰。相對於國際上熱烈的討論，國內對此議題仍極為陌生。可以預期，當個別研究結果在研究過程中出現，研究者恐怕不會特別去思考是否應向參與者揭露的問題。甚至當參與者的近用請求臨門時，研究者也恐怕對彼此間的權利義務關係一無所知。

本文認為，雖然我國法制未存在參與者對研究資料之近用的直接規範，但個資法所建立的接近權已畫設了基本的界線。亦即，倘若個別研究結果具備可識別性而構成個人資料，參與者原則上就有權請求取得。個資法第10條構成要件中「就其蒐集之個人資料」之文字、人體生物資料庫管理條例第10條的特殊規定，乃至參與同意書中可能存在之排除條款，經本文之解析可知，均不影響此項權利之行使。基此，衛生福利部發布之「人體生物資料庫參與者同意書參考格式」第十一點當中，有關否定提供參與者任何個人資料之閱覽或複製的文句，顯示對前述法秩序欠缺理解，有值得檢討修正之處。在認知到個資法接近權規定帶來的法律拘束之餘，藉著提供個別研究結果之議題，就我國個資法未對研究特設例外條款的接近權法制，也可開啟一些反省。從其他國家的立法及背後的政策考量所得之啟示，顯示適度地保留一些空間給研究者與研究倫理委員會形塑其提供近用政策，或許會比僵硬地套用個人資料保護法制下的接近權更好。當然，是否以及如何調整立法，仍視未來之發展。

在符合現行法律要求提供消極揭露之餘，研究者乃至研究機構宜秉持善意，在相關政策考量的妥適評估下，形塑積極揭露面向之規劃。參與者的接近權、參與者的偏好、隱私/機密性保護、分析

有效性、臨床價值、治療誤解風險、參與者對資料的理解與使用能力、對研究者的負擔、對醫療體系的負擔與對研究的公眾信賴等因素的複雜交錯，以及這些因素在不同研究脈絡下顯現的不同形貌，使得應如何塑造政策內容，並無絕對答案。但倘若研究的規劃與執行者願在積極揭露的面向勇敢嘗試，在告知後同意、確認與個案決定、通知等環節上，均應審慎設計，並作出彼此配合的規劃。針對告知後同意階段，本文提出三種設計方案，得依研究範圍與目標之廣狹、參與者之性質、研究規模與資源、機構之執行能力等因素，決定採行如何之設計；同時，並應有意識地透過告知內容的規劃，消弭治療誤解的疑慮。針對確認與個案決定階段，本文主張，個別研究結果未達臨床檢驗之標準，不應成為阻絕參與者近用的絕對因子，但不以經臨床檢驗為提供近用前提的研究計畫，仍應採取一定的確認程序，來擔保某程度的分析有效性；同時，研究者若欠缺相應之專業知識，應與相關專家合作，來完成臨床價值的判斷。針對通知階段，本文提出三種優劣互見之潛在作法選項，並指出其各自需求的配套措施。雖然依國內對此議題的發展現況，個別研究結果之提供近用恐怕多半被視為不必要的負擔，但希望本文的分析與建議，能稍稍緩解對提供近用實踐的陌生與遲疑。

參考文獻

1. 中文部分

- 李建良（2005），「戶籍法第八條捺指紋規定」釋憲案鑑定意見書，
台灣法學雜誌，73期，頁38-56。
- 李惠宗（2012），憲法要義，6版，臺北：元照。
- 李震山（1997），論資訊自決權，收於：李鴻禧教授六秩華誕祝賀
論文集編輯委員會編，現代國家與憲法——李鴻禧教授六秩華
誕祝賀論文集，頁709-756，臺北：月旦。
- 周慧蓮（2004），資訊隱私保護爭議之國際化，月旦法學雜誌，104
期，頁112-132。
- 林子儀（2002），基因資訊與基因隱私權——從保障隱私權的觀點
論基因資訊的利用與法的規制，收於：翁岳生教授祝壽論文集
編輯委員會編，當代公法新論（中冊）——翁岳生教授七秩誕
辰祝壽論文集，頁693-726，臺北：元照。
- 邱文聰（2009），從資訊自決與資訊隱私的概念區分——評「電腦
處理個人資料保護法修正草案」的結構性問題，月旦法學雜
誌，168期，頁172-189。
- 邱文聰、莊惠凱（2010），建置當代人類研究倫理的治理架構：一
個反身凝視的契機，人文與社會科學簡訊，12卷1期，頁33-
39。
- 洪子洵（2013），外國法與我國健保資訊應用之比較——以美國醫
療保險可攜性及責任法（HIPAA）為鑑，醫事法學，20卷2
期，頁28-45。
- 洪敏瑜（2009），醫學研究中告知後同意之法律意涵，國立清華大
學科技法律研究所碩士論文。
- 翁逸泓（2016），OTT發展之隱私與個人資料保護問題初探，世新

法學，10卷1期，頁25-85。

張腕純（2019），個資保護與公共事務資料應用之權衡——歐盟GDPR公共利益歸檔、科學或歷史研究或統計之例外規定及英國之實踐，科技法律透析，31卷2期，頁17-27。

陳仲嶙（2002），隱私權概念的理解與充填，收於：李鴻禧等著，台灣憲法之縱剖橫切，頁637-661，臺北：元照。

陳秀峰（2002），線上個人隱私之保護，月旦法學雜誌，82期，頁208-216。

陳春生（2006），事實行為，收於：翁岳生編，行政法（下冊），3版，頁1-23，臺北：元照。

陳起行（2000），資訊隱私權法理探討——以美國法為中心，政大法學評論，64期，頁297-341。

黃昭元（2005），無指紋則無身分證？——換發國民身分證與強制全民捺指紋的憲法爭議分析，收於：國際刑法學會台灣分會編，民主、人權、正義——蘇俊雄教授七秩華誕祝壽論文集，頁461-507，臺北：元照。

葉俊榮（2016），探尋隱私權的空間意涵——大法官對基本權利的脈絡論證，中研院法學期刊，18期，頁1-40。

劉靜怡（2008），「以人為對象」的研究和研究倫理委員會——以美國法制下之「言論出版自由」與「思想研究自由」為論述核心，中研院法學期刊，3期，頁201-274。

——（2019），淺談GDPR的國際衝擊及其可能因應之道，月旦法學雜誌，286期，頁5-31。

賴羿慈（2017），個人資料保護法制中研究例外規定之比較分析，國立清華大學科技法律研究所碩士論文。

顏上詠（2009），台灣人體生物資料庫管理條例草案評析，月旦法學雜誌，168期，頁155-171。

2. 外文部分

- Alessi, Stephanie A. 2013. The Return of Results in Genetic Testing: Who Owes What to Whom, When, and Why?. *Hastings Law Journal* 64:1697-1728.
- Allen, Anita L. 2011. *Privacy Law and Society*. 2d ed. Eagan, MN: West Academic Publishing.
- Allen, Nicole L., E. W. Karlson, S. Malspeis, B. Lu, C. E. Seidman, and L. S. Lehmann. 2014. Biobank Participants' Preferences for Disclosure of Genetic Research Results: Perspectives from the OurGenes, OurHealth, OurCommunity Project. *Mayo Clinic Proceedings* 89:738-746.
- Asia-Pacific Economic Cooperation [APEC]. 2005. *APEC Privacy Framework*, http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/~media/Files/Groups/ECSG/05_ecsg_privacyframewk.ashx.
- Baker, C. Edwin. 2004. Autonomy and Informational Privacy, or Gossip: The Central Meaning of the First Amendment. *Social Philosophy and Policy* 21(2):215-268.
- Beskow, Laura M., and P. Pearl O'Rourke. 2015. Return of Genetic Research Results to Participants and Families: IRB Perspectives and Roles. *The Journal of Law, Medicine & Ethics* 43:502-513.
- Beskow, Laura M., W. Burke, Stephanie M. Fullerton, and Richard R. Sharp. 2012. Offering Aggregate Results to Participants in Genomic Research: Opportunities and Challenges. *Genetics In Medicine* 14:490-496.
- Boddington, Paula. 2012. *Ethical Challenges in Genomics Research: A Guide to Understanding Ethics in Context*. Berlin: Springer-Verlag GmbH.

- Branum, Rebecca, and Susan M. Wolf. 2015. International Policies on Sharing Genomic Research Results with Relatives: Approaches to Balancing Privacy with Access. *The Journal of Law, Medicine & Ethics* 43:576-593.
- Breitkopf, Carmen Radecki, Gloria M. Petersen, Susan M. Wolf, Kari G. Chaffee, Marguerite E. Robinson, Deborah R. Gordon, Noralane M. Lindor, and Barbara A. Koenig. 2015. Preferences Regarding Return of Genomic Results to Relatives of Research Participants, Including after Participant Death: Empirical Results from a Cancer Biobank. *The Journal of Law, Medicine & Ethics* 43:464-475.
- Budin-Ljøsne, Isabelle, Harriet J. A. Teare, Jane Kaye, Stephan Beck, Heidi Beate Bentzen, Luciana Caenazzo, Clive Collett, Flavio D'Abramo, Heike Felzmann, Teresa Finlay, Muhammad Kassim Javaid, Erica Jones, Višnja Katić, Amy Simpson, and Deborah Mascalzoni. 2017. Dynamic Consent: A Potential Solution to Some of the Challenges of Modern Biomedical Research. *BMC Medical Ethics* 18(4):1-10.
- Cassa, Christopher A., Sarah K. Savage, Patrick L. Taylor, Robert C. Green, Amy L. McGuire, and Kenneth D. Mandl. 2012. Disclosing Pathogenic Genetic Variants to Research Participants: Quantifying an Emerging Ethical Responsibility. *Genome Research* 22:421-428.
- Chan, Ben, Flavia M. Facio, Haley Eidem, Sara C. Hull, Leslie G. Biesecker, and Benjamin E. Berkman. 2012. Genomic Inheritances: Disclosing Individual Research Results from Whole-Exome Sequencing to Deceased Participants' Relatives. *The American Journal of Bioethics* 12(10):1-8.
- Chen, Chung-Lin. 2009. Reconciling Family Paternalism and Autonomy in Taiwan's Health Information Law. *Australian Journal of Asian Law* 11:247-272.

- . 2010. In Search of a New Approach of Information Privacy Judicial Review: Interpretation No. 603 of Taiwan's Constitutional Court as a Guide. *Indiana International and Comparative Law Review* 20:21-46.
- Clayton, Ellen Wright, and Amy L. McGuire. 2012. The Legal Risks of Returning Results of Genomics Research. *Genetics in Medicine* 14:473-477.
- Eckstein, Lisa, J. R. Garrett, and B. E. Berkman. 2014. A Framework for Analyzing the Ethics of Disclosing Genetic Research Findings. *The Journal of Law, Medicine & Ethics* 42:190-207.
- Fabsitz, Richard R., Amy McGuire, Richard R. Sharp, Mona Puggal, Laura M. Beskow, Leslie G. Biesecker, Ebony Bookman, Wylie Burke, Esteban Gonzalez Burchard, George Church, Ellen Wright Clayton, John H. Eckfeldt, Conrad V. Fernandez, Rebecca Fisher, Stephanie M. Fullerton, Stacey Gabriel, Francine Gachupin, Cynthia James, Gail P. Jarvik, Rick Kittles, Jennifer R. Leib, Christopher O'Donnell, P. Pearl O'Rourke, Laura Lyman Rodriguez, Sheri D. Schully, Alan R. Shuldiner, Rebecca K.F. Sze, Joseph V. Thakuria, Susan M. Wolf, Gregory L. Burke, and National Heart, Lung, and Blood Institute working group. 2010. Ethical and Practical Guidelines for Reporting Genetic Research Results to Study Participants: Updated Guidelines from a National Heart, Lung, and Blood Institute Working Group. *Circulation: Cardiovascular Genetics* 3:574-580.
- Fernandez, Conrad V., P. Pearl O'Rourke, and Laura M. Beskow. 2015. Canadian Research Ethics Board Leadership Attitudes to the Return of Genetic Research Results to Individuals and Their Families. *The Journal of Law, Medicine & Ethics* 43:514-522.
- Ferriere, Michael, and B. Van Ness. 2012. Return of Individual Research

- Results and Incidental Findings in the Clinical Trials Cooperative Group Setting. *Genetics in Medicine* 14:411-416.
- Food and Drug Administration. 2005. *Guidance for Industry: Pharmacogenomic Data Submissions*, <https://www.fda.gov/downloads/drugs/guidancecomplianceregulatoryinformation/guidances/ucm079849.pdf>.
- Forsberg, Joanna Stjernschantz, Mats G. Hansson, and Stefan Eriksson. 2009. Changing Perspectives in Biobank Research: From Individual Rights to Concerns about Public Health Regarding the Return of Results. *European Journal of Human Genetics* 17:1544-1549.
- Glenn, R. A. 2003. *The Right to Privacy: Rights and Liberties under the Law*. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.
- Green, Robert C., Jonathan S. Berg, Gerard T. Berry, Leslie G. Biesecker, David P. Dimmock, James P. Evans, Wayne W. Grody, Madhuri R. Hegde, Sarah Kalia, Bruce R. Korf, Ian Krantz, Amy L. McGuire, David T. Miller, Michael F. Murray, Robert L. Nussbaum, Sharon E. Plon, Heidi L. Rehm, and Howard J. Jacob. 2012. Exploring Concordance and Discordance for Return of Incidental Findings from Clinical Sequencing. *Genetics in Medicine* 14:405-410.
- Henderson, Gail E., Larry R. Churchill, Arlene M. Davis, Michele M. Easter, Christine Grady, Steven Joffe, Nancy Kass, Nancy M. P. King, Charles W. Lidz, Franklin G. Miller, Daniel K. Nelson, Jeffrey Peppercorn, Barbra Bluestone Rothschild, Pamela Sankar, Benjamin S. Wilfond, and Catherine R. Zimmer. 2007. Clinical Trials and Medical Care: Defining the Therapeutic Misconception. *PLoS Medicine* 4(11):1735-1738.
- Henderson, Gail E., Susan M. Wolf, Kristine J. Kuczynski, Steven Joffe,

- Richard R. Sharp, D. Williams Parsons, Bartha M. Knoppers, Joon-Ho Yu, and Paul S. Appelbaum. 2014. The Challenge of Informed Consent and Return of Results in Translational Genomics: Empirical Analysis and Recommendations. *The Journal of Law, Medicine & Ethics* 42:344-355.
- Henry, Leslie Meltzer. 2006. Undesirable Implications of Disclosing Individual Genetic Results to Research Participants. *The American Journal of Bioethics* 6(6):28-30.
- Hens, Kristien, H. Nys, J. J. Cassiman, and K. Dierickx. 2011. The Return of Individual Research Findings in Paediatric Genetic Research. *Journal of Medical Ethics* 37:179-183.
- Jarvik, Gail P., Laura M. Amendola, Jonathan S. Berg, Kyle Brothers, Ellen W. Clayton, Wendy Chung, Barbara J. Evans, James P. Evans, Stephanie M. Fullerton, Carlos J. Gallego, Nanibaa A. Garrison, Stacy W. Gray, Ingrid A. Holm, Iftikhar J. Kullo, Lisa S. Lehmann, Cathy McCarty, Cynthia A. Prows, Heidi L. Rehm, Richard R. Sharp, Joseph Salama, Saskia Sanderson, Sara L. Van Driest, Marc S. Williams, Susan M. Wolf, Wendy A. Wolf, eMERGE Act-ROR Committee and CERC Committee, CSER Act-ROR Working Group, and W. Burke. 2014. Return of Genomic Results to Research Participants: The Floor, the Ceiling, and the Choices in Between. *The American Journal of Human Genetics* 94:818-826.
- Johns, Amber L., D. K. Miller, S. H. Simpson, A. J. Gill, K. S. Kassahn, J. L. Humphris, J. S. Samra, K. Tucker, L. Andrews, D. K. Chang, N. Waddell, M. Pajic, J. V. Pearson, S. M. Grimmond, A. V. Biankin, and N. Zeps. 2014. Returning Individual Research Results for Genome Sequences of Pancreatic Cancer. *Genome Medicine* 6(42): 1-8 .
- Kaye, Jane, N. Kanellopoulou, N. Hawkins, H. Gowans, L. Curren, and

- K. Melham. 2014. Can I Access My Personal Genome? The Current Legal Position in the UK. *Medical Law Review* 22:64-86.
- Knoppers, Bartha Maria. 2014. From the Right to Know to the Right Not to Know. *The Journal of Law, Medicine & Ethics* 42:6-10.
- Knoppers, Bartha Maria, and Amy Dam. 2011. Return of Results: Towards a Lexicon?. *The Journal of Law, Medicine & Ethics* 39:577-582.
- Knoppers, Bartha Maria, Mylène Deschênes, Ma'n H. Zawati, and Anne M. Tassé. 2013. Population Studies: Return of Research Results and Incidental Findings Policy Statement. *European Journal of Human Genetics* 21:245-247.
- Laurie, Graeme. 2002. *Genetic Privacy: A Challenge to Medico-Legal Norms*. New York, NY: Cambridge University Press.
- Lévesque, Emmanuelle, Joly Yann, and Simard Jacques. 2011. Return of Research Results: General Principles and International Perspectives. *The Journal of Law, Medicine & Ethics* 39:583-592.
- Maschke, Karen J. 2012. Returning Genetic Research Results: Considerations for Existing No-Return and Future Biobanks. *Minnesota Journal of Law, Science & Technology* 13:559-573.
- McGeeveran, William, Leili Fatehi, and Pari McGarraugh. 2012. Deidentification and Reidentification in Returning Individual Findings from Biobank and Secondary Research: Regulatory Challenges and Models for Management. *Minnesota Journal of Law, Science & Technology* 13:485-539.
- Middleton, Anna, Katherine I. Morley, Eugene Bragin, Helen V. Firth, Matthew E. Hurles, Caroline F. Wright, Michael Parker, and D. D. D. Study. 2016. Attitudes of Nearly 7000 Health Professionals, Genomic Researchers and Publics toward the Return of Incidental Results from Sequencing Research. *European Journal of Human*

Genetics 24:21-29.

Murphy, Juli, Joan Scott, David Kaufman, Gail Geller, Lisa LeRoy, and Kathy Hudson. 2008. Public Expectations for Return of Results from Large-Cohort Genetic Research. *The American Journal of Bioethics* 8(11):36-43.

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2018. *Returning Individual Research Results to Participants: Guidance for a New Research Paradigm*. Washington, D.C.: The National Academies Press.

National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. 1979. *The Belmont Report*, <https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/read-the-belmont-report/index.html>.

National Institutes of Health. 2004. *Clinical Research and the HIPAA Privacy Rule*. NIH Publication Number 04-5495, https://privacyruleandresearch.nih.gov/pdf/clin_research.pdf.

———. 2018. *All of Us Research Program Protocol*. v1.7, https://allofus.nih.gov/sites/default/files/aou_operational_protocol_v1.7_mar_2018.pdf.

Organization for Economic Cooperation and Development. 1980. *OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data*, <https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflowsofpersonaldata.htm>.

———. 2009. *Guidelines on Human Biobanks and Genetic Research Databases*, <https://www.oecd.org/sti/biotech/44054609.pdf>.

———. 2013. *The OECD Privacy Guidelines*, http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf.

Ortiz-Osorno, Alberto (Betto), Linda A. Ehler, and Judith Brooks. 2015. Considering Actionability at the Participant's Research Setting

- Level for Anticipatable Incidental Findings from Clinical Research. *The Journal of Law, Medicine & Ethics* 43:619-632.
- Parker, Lisa S. 2012. Returning Individual Research Results: What Role Should People's Preferences Play?. *Minnesota Journal of Law, Science & Technology* 13:449-484.
- Petersen, Gloria M., and B. Van Ness. 2015. Returning a Research Participant's Genomic Results to Relatives: Perspectives from Managers of Two Distinct Research Biobanks. *The Journal of Law, Medicine & Ethics* 43:523-528.
- Pike, Elizabeth R., Karen H. Rothenberg, and Benjamin E. Berkman. 2014. Finding Fault? Exploring Legal Duties to Return Incidental Findings in Genomic Research. *The Georgetown Law Journal* 102:795-843.
- Precision Medicine Initiative (PMI) Working Group. 2015. *The Precision Medicine Initiative Cohort Program – Building a Research Foundation for 21st Century Medicine*, <https://www.nih.gov/sites/default/files/research-training/initiatives/pmi/pmi-working-group-report-20150917-2.pdf>.
- Prince, Anya E.R., John M. Conley, Arlene M. Davis, Gabriel Lázaro-Muñoz, and R. Jean Cadigan. 2015. Automatic Placement of Genomic Research Results in Medical Records: Do Researchers Have a Duty? Should Participants Have a Choice?. *The Journal of Law, Medicine & Ethics* 43:827-842.
- Ramoni, Rachel B., A. L. McGuire, J. O. Robinson, D. S. Morley, S. E. Plon, and S. Joffe. 2013. Experiences and Attitudes of Genome Investigators Regarding Return of Individual Genetic Test Results. *Genetics in Medicine* 15:882-887.
- Reiser, Stanley Joel. 2002. The Ethics Movement in the Biological and Health Sciences: A New Voyage of Discovery. Pp. 3-18 in *The*

- Ethical Dimensions of the Biological and Health Sciences*. 2d ed., edited by Ruth Ellen Bulger, Elizabeth Heitman, and Stanley Joel Reiser. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
- Renegar, Gaile, Christopher J. Webster, Steffen Stuerzebecher, Lea Harty, Susan E. Ide, Beth Balkite, Taryn A. Rogalski-Salter, N. Cohen, Brian B. Spear, Diane M. Barnes, and Celia Brazell. 2006. Returning Genetic Research Results to Individuals: Points-to-Consider. *Bioethics* 20:24-36.
- Scholtes, Emily. 2016. Note, Incorporating Cost into the Return of Incidental Findings Calculus: Defining a Responsible Default for Genetics and Genomics Researchers. *Minnesota Law Review* 100:1171-1208.
- Scollon, Sarah, K. Bergstrom, L. B. McCullough, A. L. McGuire, S. Gutierrez, R. Kerstein, D. W. Parsons, and S. E. Plon. 2015. Pediatric Cancer Genetics Research and an Evolving Preventive Ethics Approach for Return of Results after Death of the Subject. *The Journal of Law, Medicine & Ethics* 43:529-537.
- Solove, Daniel J. 2004. *The Digital Person: Technology and Privacy in the Information Age*. New York, NY: New York University Press.
- Solove, Daniel J., and Marc Rotenberg. 2003. *Information Privacy Law*. New York, NY: Aspen Law & Business.
- Steinsbekk, Kristin Solum, B. Kåre Myskja, and B. Solberg. 2013. Broad Consent versus Dynamic Consent in Biobank Research: Is Passive Participation an Ethical Problem?. *European Journal of Human Genetics* 21:897-902.
- Tassé, Anne Marie. 2011. The Return of Results of Deceased Research Participants. *The Journal of Law, Medicine & Ethics* 39:621-630.
- The Precision Medicine Initiative (PMI) Working Group. 2015. *The Precision Medicine Initiative Cohort Program – Building a*

Research Foundation for 21st Century Medicine, <https://www.nih.gov/sites/default/files/research-training/initiatives/pmi/pmi-working-group-report-20150917-2.pdf>.

Turkington, Richard C., and Anita L. Allen. 2002. *Privacy Law: Cases and Materials*. 2d ed. St. Paul, MN: West Group.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 2003. *International Declaration on Human Genetic Data*, http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17720&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

Westin, Alan F. 1967. *Privacy and Freedom*. New York, NY: Atheneum Press.

Wolf, Susan M. 2012. The Past, Present, and Future of the Debate over Return of Research Results and Incidental Findings. *Genetics in Medicine* 14:355-357.

Wolf, Susan M., Brittney N. Crock, Brian Van Ness, Frances Lawrenz, Jeffrey P. Kahn, Laura M. Beskow, Mildred K. Cho, Michael F. Christman, Robert C. Green, Ralph Hall, Judy Illes, Moira Keane, Bartha M. Knoppers, Barbara A. Koenig, Isaac S. Kohane, Bonnie Leroy, Karen J. Maschke, William McGeeveran, Pilar Ossorio, Lisa S. Parker, Gloria M. Petersen, Henry S. Richardson, Joan A. Scott, Sharon F. Terry, Benjamin S. Wilfond, and Wendy A. Wolf. 2012. Managing Incidental Findings and Research Results in Genomic Research Involving Biobanks and Archived Data Sets. *Genetics in Medicine* 14:361-384.

Wolf, Susan M., Frances P. Lawrenz, Charles A. Nelson, Jeffrey P. Kahn, Mildred K. Cho, Ellen W. Clayton, Joel G. Fletcher, Michael K. Georgieff, Dale Hammerschmidt, Kathy Hudson, Judy Illes, Vivek Kapur, Moira A. Keane, Barbara A. Koenig, Bonnie S. Leroy, Elizabeth G. McFarland, Jordan Paradise, Lisa S. Parker, Sharon F.

- Terry, Brian Van Ness, and Benjamin S. Wilfond. 2008. Managing Incidental Findings in Human Subjects Research: Analysis and Recommendations. *The Journal of Law, Medicine & Ethics* 36:219-248.
- Wolf, Susan M., Rebecca Branum, Barbara A. Koenig, Gloria M. Petersen, Susan A. Berry, Laura M. Beskow, Mary B. Daly, Conrad V. Fernandez, Robert C. Green, Bonnie S. LeRoy, Noralane M. Lindor, P. Pearl O'Rourke, Carmen R. Breitkopf, Mark A. Rothstein, Brian Van Ness, and Benjamin S. Wilfond. 2015. Returning a Research Participant's Genomic Results to Relatives: Analysis and Recommendations. *The Journal of Law, Medicine & Ethics* 43:440-463.
- Zawati, Ma'n H., and Bartha Maria Knoppers. 2012. International Normative Perspectives on the Return of Individual Research Results and Incidental Findings in Genomic Biobanks. *Genetics in Medicine* 14:484-489.

Biomedical Research Participants' Access to Individual Research Results:

The Application of Laws and Formulation of Policies

*Chung-Lin Chen**

Abstract

Researchers may produce and acquire certain information that is valuable for the health of individual participants. Are participants entitled to access to the research results that are related to them if they make such a request of researchers? What policy should researchers adopt to determine the disclosure of individual research results to participants? The issue regarding the return of results has attracted heated debate. Against this backdrop, this article intends to explore the right of access to individual research results and to offer suggestions on formulating a research policy of providing access.

This article argues that the right of access to personal data granted by the Personal Data Protection Act constitutes a precondition to the relationship between participants and researchers in terms of the return of results. In addition to the right of access to personal data, other nine factual and ethical factors should be carefully taken into account to formulate an adequate policy of providing access. And such policy should be coherently structured in the segments of informed consent, confirming results, determining whether to return the results to the participant, and executing the return of the results.

KEYWORDS: return of results, research findings, incidental findings,

* Professor and Director, Institute of Law for Science and Technology, National Tsing Hua University.

biobank, right of access to personal data, analytic validity, clinical value, therapeutic misconception, dynamic consent.